جامعة المستقبل
كلية الشريعة
قسم أصول الفقه

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس

بعنوان

:أحكام الحضانة في الفقه الإسلامي

إعداد: أيانة عبد محمد .

الرقم الجامعي: ٣٨٥٣٢.

الإشراف: الدكتور: عبد العزيز أحمد علي

العام الدراسي :هـ١٤٤٢-الموافق ٢٠٢٠م


بسم الله الرحمن الرحيم

الإستهلال :

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيۡهَا زَكَرِيَّا ٱلۡمِحۡرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزۡقًا ۖ قَالَ يَٰمَرۡيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتۡ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾[1]

١ – سورة آل عمران جزء من الآية ٣٧.


بسم الله الرحمن الرحيم

إهداء :

- إلى من شجعني على المثابرة طوال عمري، إلى الرجل الأبرز في حياتي (والدي العزيز)
- إلى من بها أحب، وعليها أرتكز، إلى القلب المعطاء (والدتي الحبيبة)
- إلى إخوتي وشقيقاتي لا غناء عنهن حفظهن الله
- إلى صديقاتي خاصة وسائر المسلمات عامة
- إلى أساتذتي في كلية الشريعة الإسلامية
- إلى كل من ساهم ولو بحرف في حياتي الدراسية
- إلى كل هؤلاء: أهدي هذا العمل، الذي أسأل الله ان يتقبله خالصا

كلمة الشكر والتقدير:

أشكر الله تعالى أولا وآخرا.

ثم أشكر والدي الحبيبين الذين ساهما في وصولي عليا، في مجال دراسة علم الشرعي فكلمات الثناء لا توفيكم حقكم، فشكرا لكم على إعطائكم الدائم، وأطال الله بقائكما.

وأشكر ايضا إدارة الجامعة، ولولاكم لم نكن لنصل إلى أفضل المراتب، ولولا جهودكم لما كان للنجاح أي وصول، ولما تحققت الأهداف، فشكرا لكم وإلى الأمام دائما، كان الله عونكم ومعينكم،

أخيرا أشكر أستاذي د/ عبد العزيز، إليك يا من بذلت ولم تنتظر العطاء، إليك أهدي كلمات شكر وتقدير تليق بك، ولن أنسى وقفتك إلى جانبي، لك مني كل الثناء والتقدير على جهودك الثمينة والقيمة، كان الله معك.

المقدمة

الحمد لله الذي لم يخلق العباد عبثا، ولم يتركهم سدى، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الفرد الصالح هو أساس الأسرة الفاضلة، والأسرة هي نواة المجتمع الخير ولهذا فإن الإسلام غني بالفرد منذ نعومة أظفاره، بل قبل ذالك عندما أمر الرجل ان يختار الزوجة الصالحة والنبت الحسن، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنشئة الطفل تنشئة صالحة فقال: "كل مولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه "ولهذا فإن الحضانة في الإسلام لها أهمية خاصة، وخطورة بالغة من أجل ذالك أوجبها الإسلام على الأب او من ينوب عنه، في الوفات او العجز. وتزداد أهمية الحضانة ويعظم قدرها عندما يفترق الزوجان وتنشأ بينهما نزاعات وخصومات تعرض الطفل لمخاطرة كبيرة والإنحرافات مثيرة ، يلتزم الطرفان المتنازعان بالأحكام والآداب المرعية ويتقي الله أنفسهما وأولادهما.

وبعد...

فهذا بحث عن تعريف الحضانة وحكمها ومن الذي تجب له الحضانة، ومن أولى الناس بالحضانة ونحو ذالك.

أسباب إختيار هذا الموضوع:

١. سبب التنبيه على أن حضانة الطفل ليست فقط أن تبنى الجسد والجسم إنما هي أيضا بناءه عقليا وروحيا ونفسيا حتى يكون قادرا لمواجهة التعب ومشقة الدنيا.

٢. رعاية الطفل وتعليمه بحقوق الله عليه وكيفية أداء أمانة الله، وحقوق الناس حتى يكون إجتماعيا يحترم فيمن حوله وغير ذالك من حقوق الناس.

٣. أن كثيرا من الناس في هذا الزمن أهملو في حضانة الأطفال ورعايتهم،

٤. كثرة الطلاق في هذا الزمن حيث أن الطلاق تساهم في ضياع الأطفال وحضانتهم

أهمية الموضوع:

.أنها حجر الأساس الذي تبنى عليه شخصية الإنسان.

.تفيد الطفل بالتعرف على العالم الخارجي الذي يحيط به وفهمه والتعامل معه.

.تكسب الطفل سلوكيات جيدة تساعد الأسرة في دورها في تربيته ونشأة الطفل.

.تساهم الحضانة في تكوين شخصية الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.

.نشأة الطفل معتمدا بنفسه والقيام بأموره بمفرده وهذا من خلال تعليمه ذالك.

.نشأة الطفل مدرك ا لحقوق الآخرين ومحترما لها

أهداف البحث:

١. التنبيه على رعاية الأطفال إجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

٢. تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمة الدينية.

٣. دور الحضانة لتقوية وتنمية الروابط الإجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.

أسئلة البحث:

ما هي الحضانة في الإسلام؟

ما حكمة الحضانة؟

هل الحضانة الطفل واجبة ام لا.؟

ما هي ماهية الحضانة؟

فرضيات البحث:

١. هي حضانة الأم لولدها: اي ضمها إياه إلى جنبها وإعتزالها إياه من أبيه ليكون عندها فتقوم بحفظه وإمساكه وغسل ثيابه والعناية به وإعطائه جميع حقوقه.

٢. الحضانة فيها حفظ المحضون؛ لذالك قدمت الأم في حضانة ولدها حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير النساء، وتتحول الحضانة إلى الأب في حالة كون الصغر قد بلغ حدا يعرب فيه عن نفسه، ويستغني عن الحمل والوضع.

٣. واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، او وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره، لأنه قد يهلك، أو يتضرر بترك الحفظ.

٤. القيام على تربية الطفل وتنشئته ورعايته وحفظه.

حدود البحث:

الحد الموضوعي:

إحتوى هذا البحث على أحكام الحضانة الوارة في الكتاب والسنة ومن ثم درستها دراسة فقهية.

الحد الزماني: ١٤٤٢ هـ الموافق: ٢٠٢٠

الحد المكاني: جامعة المستقبل.

أدوات البحث:

١- المصادر والمراجع .

٢-المكتبات الكترونية.

٣- الرسائل الجامعية.

٤- الحاسوب.

منهج البحث:

المنهج الذي تستخدمه الباحثة في هذا الموضوع هو المنهج الإستقرائي التتبعي ومن خلال هذا المنهج اتبعة الباحثة الطريقة الإجرائية الآتية:

١.درست المسائل الفقهية الواردة في كتب الفقه من الحضانة.

٢. غزوت الآيات على المصحف وذالك بإسم السورة ورقم الآية وذالك في الهامش.

٣. عرفت المصطلحات والكلمات الغريبة الواردة في البحث.

ذبلت البحث بفهارس علمية وهي كالآتي:

فهرس الآيات.

فهرس الأحاديث.

فهرس الموضوعات.

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس المصطلحات.

هيكل البحث:

ويتكون من فصلين، وخاتمة وهي كالتالي:

الفصل الأول: أساسيات البحث.

وتتكون من:

١. مقدمة

٢. أسباب إختيار الموضوع

٣. أهمية البحث

٤. أهداف البحث

٥. أسئلة البحث

٦. فرضيات البحث

٧. حدود البحث

١٠. أدوات البحث

١١. منهج البحث

الفصل الثاني:تعريف الحضانة في الفقه الإسلامي. وفيه سبعة مباحث.

المبحث الأول: تعريف الحضانة،وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: مفهوم الحضانة.

المطلب الثاني: حكم الحضانة.

المطلب الثالث: مشروعية الحضانة.

المطلب الرابع:حكمة مشروعية الحضانة.

المبحث الثاني: شروط الحضانة ، شروط العامة بين النساء والرجال، شروط خاصة بالنساء ، شروط خاصة بالرجال ،وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول: شروط مستحقي الحضانة المشتركة بينهم.

المطلب الثاني: شروط خاصة بالنساء .

المطلب الثالث: شروط خاصة بالرجال.

المبحث الثالث: ترتيب الحضانة، مسقطات الحضانة، عودة الحق في الحضانة، وفيه ثلاث مطالب.

المطلب الأول: :ترتيب الحضانة .

المطلب الثاني: سقوط الحضانة.

المطلب الثالث: عودة الحق في الحضانة.

المبحث الرابع: ثبوت الحضانة للعصبة، إجتماع العصبة مع غيرهم، أجرة الحضانة، مدة الحضانة،فيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ثبوت الحضانة العصبة، وفيه ثلاثة فروع.

الفرع الأول: ثبوت الحضانة للأب.

الفرع الثاني: ثبوت الحضانة للجد.

الفرع الثالث: ثبوت الحضانة لسائر العصبة.

المطلب الثاني: إجتماع العصبة مع غيرهم. وفيه سبعة فروع.

الفرع الأول: إجتماع الأب والجدة أم الأب.

الفرع الثاني: إجتماع الأب مع الخالة.

الفرع الثالث: التخيير بين العصبة والأم في الحضانة.

الفرع الرابع: إجتماع الأخت لغير أم مع الأخت من الأم.

الفرع الخامس: إسقاط الأم حقها في الحضانة.

الفرع السادس: إجتماع الجد مع الأخت من الأب.

الفرع السابع: إجتماع المتساويين في الحضانة

المطلب الثالث: أرة االحضانة.

المطلب الرابع: بداية الحضانة ونهايتها.

الخاتمة، وفيها

. النتائج.

. التوصيات.

. الفهارس.

الفصل الأول :مفهوم الحضانة، حكم الحضانة ،مشروع الحضانة حكمة مشروعية الحضانة ،شروط إستحقاق الحضانة، ترتيب الحضانة ،وفيه ثلاث مباحث :

المبحث الأول تعريف الحضانة، حكم الحضانة ،مشروعية الحضانة ،حكمة مشروعية الحضانة،وفيه أربعة مطالب :

المبحث الثاني :شروط إستحقاق الحضانة، شروط خاصة بالنساء وشروط خاصة بالرجال، وفيه ثلاثة مطالب :

المبحث الأول تعريف الحضانة، حكم الحضانة ،مشروعية الحضانة حكمة مشروعية الحضانة. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحضانة لغة واصطلاحا.

الحضانة لغة مأخوذة من الحضن: وهو الجنب، وهي الضم إلى الجنب.

وشرعا: عرف الفقهاء بتعريفات متعددة:

قال الحنفية: الحضانة هي تربية الولد لمن له حق الحضانة،[١]وحضانة الأم ولدها هي ضمها إياه إلى جنبها واعتزالها إياه من أبيه ليكون عندها فتقوم بحفظه وامساكه وغسل ثيابه[٢]

وقال المالكية: هي صيانة العاجز والقيام بمصالحه[٣] وعند الشافعية: هي تربيته ومراعاة مصلحته في يعجز ولا يميز بين ضرها ونفعها [٤]

وعند الحنابلة: هي حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو المختل العقل عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم من غسل بدن وثوب وتكحيل ودهن وربط بمهد وتحريكه لينام [٥]

٥- مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني ج٥ ص٦٦٥/ المكتب الإسلامي- الطبعة الثانية ١٤١٥هـ-١٩٩٤م.

٦-نهاية المحتاج للرميلي ج٧ ص٢٢٥/ دار الفكر بيروت.

٧- البدائع: ج٤ ص ٤٠، الشرح الصغير: ج٢ ص٧٥٦، مغني المحتاج: ج٣ ص٤٥٢، كشاف القناع: ج٥ ص٥٧٦.

٨-الولاية بالفتح والكسر: النصرة.(مختار الصحاح ج١ ص٤٣٥) وقال الجرجاني: هي تنفيذ القول على الغير شاء الغير أم أبى.(التعريفات للجرجاني ج١ ص٢٤٥.

وقال الرميلي: حفظ من لا يستقل وتربيته بما يصلحه وبقية عما يضره [٦]

والملاحظة من التعرفات السابقة للحضانة أنها كلها تدور حول حفظ الصبي وصيانته في وقت يعجز فيه عن الأداء بمهامه، ولا يستقل بأمور نفسه من طعام وشراب ونحوها. **والتعريف**

المختار: هي

تربية الولد لمن له حق الحضانة . أو هي تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه، كطفل وكبير مجنون. وذالك برعاية شؤونه وتدبير طعامه وملبسه ونومه، وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه في سن معينة ونحوها.[٧] والحضانة نوع ولاية وسلطنة[٨]، لكن الإناث أليق بها ؛ لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال، فإذا بلغ الطفل سنا معينة، كان الحق في تربيته للرجل؛ لأنه أقدر على حمليته وصيانته وتربيته من النساء.

الألفاظ ذات صلة بالحضانة.

أ-الكفالة ٢-الكفلة لغة الضم ، وكفلت المال وبالمال ضمنته' وكفلت الرجل وبالرجل كفلا وكفالة ، وتكفلت به ضمنته ، والكافل العائل والكافل والكفيل الضامنقل ابن الأعرابي :كفيل كافل وضمين وضامن بعنى واحد،

وفي التهذيب: وأما الكافل فهو الذي كفل إنسانا يعوله وينفق عليه، وقال إبن بطال: الكفالة بالولد أن يعوله ويقوم بأمره، ومنه قوله تعالى :{وكفلها زكريا}

والفقهاء يفردون بابا للكفالة بالدين أو بالنفس، ويعرفون بأنها ضم ذمة الكفيل إلي ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا بنفس ،او بدين أو عين كمغصوب، كما يستعملون لفظ الكفالة في باب الحضانة، ويريدون بالكفيل من يعول الصغير ويقوم بأموره. وعلى ذالك فلفظ الكفالة مشترك بين ضم الذمة وبين الحضانة.[١]

ب- الولاية:

الولاية لغة: النصرة ، وشرعا : القدرة على التصرف أو هي : تنفيذ القول على الغير. وقد يكون مصدها الشرع كولاية الاب والجد . وقد يكون مصدرها تفويض الغير كالوصاية ونظارة الوقف . والولايات متعددة كالولاية في المال ، وفي النكاح وفي الحضانة وتختلف من تثبت له الولاية من نوع الى نوع ، فقد تكون للرجال فقط. وقد تكون للرجال والنساء. والحضانة نوع من أنواع الولايات الثابتة بالشرع ، ويقدم فيها النساء على الرجال.

ج- الوصاية لغة: الأمر ، وشرعا :الأمر بالتصرف بعد الموت كوصية الإنسان إلى من يغسله ، أو يصلي عليه إماما ، أو يزوج بناته ونحو ذالك ، فالوصاية ولاية كغيرها ، إلا أنها تثبت بتفويضالغير ، اما الحضانة فهي بالشرع ، وقد يكون الوصي حاضنا.

المطلب الثاني: حكم الحضانة.

[١]ذهب الفقهاء إلى حكم وجوبها على الكفاية، إذا قام بها من يصلح لها ، سقط الإثم عن الباقين، وذالك لأن المحضون محتاج إلى الإعتناء والصيانة فإنه إن ترك ضاع وهلك، فيجب إحياءه وحفظه عن الهلاك.[٩]

وقد تتعين كما إذا لم يكن للطفل إلا أمه،أو كانت لكنه لا يقبل إلا غيرها، أو لم يكن للأب، ولا للصغير مال،او لم يكن للصغير ذو رحم محرم، وقد تكون جائزة كما إذا كانت للطفل لم تزوجت من غير أبيه.والأب قادر على توفير حاضنة له، مستوفية لشروط إستحقاق الحضانة،وقد تكون محرمة إذان الحاضن كافرا يستبيح الكبائر والموبقات.[١٠]

٩- المهذب للشيرازي ج٣ ص١٦٤/ دار الكتب العلمية، الكافي في فقه الإمام أحمد ج٣ ص٢٤٤/ دار الكتب العلمية، مطالب أولى النهى ج٥ ص٦٦٥/ المكتب الإسلامي، الروضة الندية للقنوجي ج٢ ص٩١/دار إبن عفان.

١٠-الفتاوى الهندية لأبي المظفر ج١ ص٥٤١، حاشية در المختار على الدر المختار ج٣ ص٥٥٩، المقدمات الممهدات ح٢ ص٤٣٧، حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة بن أبي زيد وهي حاشية العلامة الشيخ على الصعيدي العدوي ح٢ ص١٢٩، ١٣٠/ طبعة دار إحياء الكتب العربية- عيسى ألبابي الحلبي وشركاه، حاشيتا قليوبي وعميرة ح٤ ص٩٢/ مطبعة مصطفى ألبابي الحلبي/ الطبعة الثالثة ١٣٧٥هـ-١٩٥٦م.

المطلب الثالث:مشروعية الحضانة.

الحضانة مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب فآيات كثيرة منها ما يلي:

١-قوله تعالى في الأبوين: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾

(١١)

وجه الدلالة:

خص الله تبارك وتعالى التربية بالذكر في قوله(كما ربياني) ليتذكر العبد شفقة الأبوين، وتعبها.

في التربية، فيزيده ذالك إشفاقا لهما؛ وحنانا عليهما(١٢)

وقال الطبري: أي أدع الله لوالديك بالرحمة، وقل رب ارحمهما، وتعطف عليهما بمغفرتك، ورحمك كما تعطفا علي في صغري، فرحماني وربياني
حتى إستقللت بنفسي، واستغنيت عنها١) فكان ذالك دليلا على وجوب حضانة المولود.[١]

١١ سورة الإسراء جزء من الآية ٢٤.

١٢-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١٠ ص٢٤٤/دار الكتب المصرية بالقاهرة.

١٣-جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي بن جرير الطبري ج١٧ ص٤٢٠/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة الأولى. ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م.

٢- قوله تعالى في الأمهات: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣﴾ البقرة: ٢٣٢

(١٤)فالأم أحق برضاعة إبنها وحضانته إلى أن يستغني عنها بنفسه.

٣- قوله سبحانه حاكيا عن أخت موسى-صلى الله عليه وسلم- أنها قالت لآسية امرأة فرعون(قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿۞وَحَرَّمۡنَا عَلَيۡهِ ٱلۡمَرَاضِعَ مِن قَبۡلُ فَقَالَتۡ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰٓ أَهۡلِ بَيۡتٖ يَكۡفُلُونَهُۥ لَكُمۡ وَهُمۡ لَهُۥ نَٰصِحُونَ ١٢﴾

(١٥)

وجه دلالة:

دلت الآية الكريمة على مشروعية الحضانة؛ في قوله: (هل أدلكم على من يكفله) أي: هل أدلكم على من يضمه إليه فيحفظه فيحفظه ويرضعه ويربيه (١٦)

١٤-سورة البقرة جزء من الآية ٢٣٣.

١٥-سورة القصص جزء من الآية ١٢،١٣.

١٦-جامع البيان في تأويل القرآن ج١٨ص٣٠٥.

وأما السنة: فأحاديث منها ما يلي:

١ما روى عن علي –رضي الله عنه– قال: (خرج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنة

حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها؛ أنا أحق بها، إبنة عمي وعندي خالتها وإنما – الخالة أم، فقال علي: أنا أحق بها إبنة عمي، وعندي إبنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم– وهي أحق بها، فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها، فخرج النبي–صلى الله عليه وسلم– فذكر حديثا قال: (وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم)[١٧]

وجه دلالة:

في الحديث دليل على أن الخالة في الحضانة بمنزلة الأم، حيث قضى –صلى الله عليه وسلم بابنة حمزة لجعفر؛ لموضع خالتها أسماء بنت عميس، فكان دليلا على مشروعة الحضانة[١٨]

٢–ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو (أن إمرأة قالت: يا رسول الله إن إبني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له

حواء، وإن أن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- (أنت أحق به ما لم تنكحي[١٩]

وجه دلالة:

في الحديث دليل على أن الأم احق بحضانة ولدها إذا أراد الأب إنتزاعه منها وقد ذكرت هذه المأة صفات إختصت بها تقتضي إستحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها، وأقرها النبي ..... على ذالك وحكم لها،ونبه الحديث على معنى المقتضي للحكم، وان العلل والمعاني المعتبرة في إثبات الأحكام المستقرة في الفطر السليمة، فكان دليلا على مشروعية الحضانة.[٢٠]

وأما الإجماع:

فلا خلاف بين أحد من أحد من الأمة في إيجاب كفالة الأطفال الصغار؛ لأن الإنسان خلق ضعيفا مفتقرا إلى من يكفله ويربيه؛ حتى ينفع نفسه وستغي بذاته،

١٧- أخرجه أبو داود في سننه/ كتاب الطلاق/باب من أحق بالولد ج٦ ص٣٧٤ رقم ٢٢٧٩، وسكت عنه فهو أحسن.

١٨- عون المعبود لأبي الطيب آبادي ج٦ ص٣٧١/ دار الكتب العلمية ، بيروت.

١٩- أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق/ باب من أحق بالولد ج٦ ص٣٧١ رقم ٢٢٧٧.

٢٠- سبل السلام للصنعاني ج٣ ص١٥٦٠/ دار الفكر ١٩٩٥م.

٢١- نقل هذا الإجماع ابن رشد القرطبي. أنظر: المقدمات الممهدات ج١ ص٥٦٤/دار الغرب الإسلامي/ الطبعة الأولى . ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.

فهو من فروض الكفاية لا يحل أن يترك الصغير دون كفالة ولا تربية حتى يهلك، ويضيع، وإذا قام به قائم سقط الإثم عن الناس، ولا يتعين ذالك سوى الأب وحده، ويتعين على الأم حولي رضاعه [٢١]

وتتجلى الحكمة من مشروعية الحضانة في إغاثة المحضون، وإثابة الحاضن، وتحقيق التكافل الإجتماعي، وإحترام النفس البشرية.

المطلب الرابع: حكمة مشروعية الحضانة.

شرع الإسلام حضانة الطفل لإعطائه حقوقه في الرعاية والحماية' وتعاهدا لبنائه وتعليمه، فالفطرة السوية تقتضي تعاهد الأبناء وحمايتهم وإطعامهم وتربيتهموبذل الوسع في تنشئتهم بما يليق بظروف الزمان والمكان والإنسان وقد أقرت الشرائع السماوية تشريعات تفرط حفظ النفس على تعدد وجوه الحفظ والرعاية، وحفظ المحضون مرسل على التربية والتنمية والإصلاح والإطعام والتعليم والإمساك عن الأذى للنفس أو للغير' وفي ذالك موافقة لما جاءت به الشرائع وألمحت إليه الفطرة

المبحث الثاني: شروط إستحقاق الحضانة.

حرصت الشريعة الإسلامية على تنشئة الطفل تنشئة سليمة، فحددت شروطا لإستحقاق الحضانة، منه ما هو مشتركة بين النساء والرجال، ومنه ما هو خاص بالنساء وخاص بالرجال، وفيما يلي عرض لهذه الشروط بالتفصبل.

المطلب الأول: شروط المشتركة بين النساء والرجال.

يشترط في الحاضن من النساء والرجال في ثمانية شروط مجتمعة. لإستحقاق الحضانة.الشرط الاول: الإسلام.إختلف الفقهاء في إشتراط إسلام الحاضن على مذهبين.

المذهب الأول: إشتراط

إسلام الحاضن ذكرا كان أو انثى، إذا كان المحضون مسلما، وبه قال جمهور الفقهاء الشافعية [٢٢] والحنابلة [٢٣] وغيرها :

المذهب الثاني:

عدم إشتراط إسلام الحاضن ذكرا كان أو أنثى، إذا كان المحضون مسلما ما لم يعقل المحضون الأديان، أو يخاف أن يألف الكفر، وهو قول الحنفية [٢٤] والمالكية[٢٥] والظاهرية[٢٦]

[١]سبب الإختلاف:

يرجع سبب إختلاف الفقهاء في توفر شرط الإسلام في الحاضن إلى إختلافهم في تأثير الكفر على المحضون، فمن خشي تأثيره عليه، لملازمة المحضون للحاضن في فترة الحضانة، قال باشتراط الإسلام في الحاضن، ومن رأى أنه لا تأثير له يذكر، طالما أن المحضون لم يعقله، قال بعدم إشتراط الإسلام في الحاضن[٢٧]

الأدلة الجمهور:

إستدل جمهور الفقهاء على إشتراط إسلام الحاضن بالكتاب، والسنة،

أما الكتاب: فقوله تعالى.(**ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا**)[٢٨]

وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على أنه لا ولاية لكافر على مسلم، والحضانة ولاية، فلا تجوز للكافر على المسلم.

٢

٢٢- البيان في مذهب إمام الشافعي ج١١ ص٢٧٥، الإقناع الخطيب الشربيني ج٢ ص٤٩١/ دار الفكر بيروت.

٢٣-الكافي في فقه الإمام أحمد ج٣ ص٢٤٥.

٢٤-شرح فتح القدير للكمال بن المهام ج٨ ص٣١٠ / دار الكتب العلمية.

٢٥-شرح مختصر الخليل للخرشي ج٤ ص٢١٢/ دار الفكر.

٢٦- المحلى لابن حزم ج١٠ ص١٤٣/ دار الفكر بيروت.

-٢٧

[1]وأما السنة: فما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه/قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم) كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء[٢٩]؟)[٣٠].

وجه الدلالة: دل الحديث أن كل من ولد على الفطرة، وكان له أبوان على غير الإسلام هوداه أو نصراه مما يدل على تأثيرهما فيه[٣١]

وأما المعقول: فإن حضانة الكافر للمسلم ظاهره الضرر، حيث يخشى على الطفل من ان تدعوه إلى الكفر فينحرف وراء كلامها؛ مما يؤدي إلي فساده[٣٢]

ادلة مذهب الثاني:

٢٨- سورة النساء جزء من الآية ١٤١.

٢٩- جدعاء: أي مقطوعة الأطراف . النهاية في غريب الحديث والأثر لابن أثير ج١ ص٢٤٧ / المكتبة العلمية بيروت، ٥١٣٩٩- ١٩٧٩م.

٣٠- أخرجه البخاري في صحيحه، واللفظ له/ كتاب الجنائز/ باب ما قيل في أولاد المشركين ج١ص٤٦٤ رقم ١٣٦١، مسلم في صحيحه/ كتاب القدر/ باب كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ج١٦ ص ١٧٧ رقم ٦٠٧٦.

٣١- عمدة القاري للعيني ج٨ ١٦٨/ دار الفكر.

٣٢- الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين ج١٣ ص٥٣٨ بتصرف/ دار ابن الجوزي/ الطبعة الأولى ١٤٢٢-١٤٢٨هـ.

إستدل الحنفية ومن وافقهم على عدم إشتراط إسلام الحاضن بالمعقول، فقالوا: إن حق الحضانة بإعتبار الشفقة، وذالك لا يختلف بإختلاف الدين، فيكون الدفع إليها أنظر له، ما لم يعقل الأديان، فإذا عقل ينزع منها لإحتمال الضرر[٣٣]

الراجح:

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم، تبين لي- والله تعالى أعلم- أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول باشتراط كون الحاضن مسلما هو الرجح في نظري، وذالك لأسباب الآتية:

١-قوة أدلتهم

٢- إن الفسق يمنع إستحقاق الحضانة عند جمهور الفقهاء؛ لئلا يؤدي إلى ضياع المحضون، فالكفر أولى منه إذ فيه هلاكه.

١

٣- إن الحضانة أثرا كبيرا في حياة المحضون، حيث تعتبر مرحلة مهمة في التنشئة أولى للطفل، ولا يمكن مراقبة تصرفات الحاضن غير المسلم مع المحضون، فالقول باشتراط الإسلام أولى بالقبول.

الشرط الثاني: العقل والبلوغ.

٣٣- تبيين القائق للزيلعي ج٣ ص٤٩/ المطبعة الكبرى الأميرية، العناية على الهداية للبابرتي ج٤ ص٣٦٩.

فلا حضانة لمجنون، وإن كان جنونه منقطعا؛ لأنها ولاية، وليس هو من اهلها، ولا لمن به طيش ، زلا يتأتى منه الحظ ولا التعهد بل هو في نفسه يحتاج إلى من يحضنه[٣٤] ولا حضانة لصبي لأنه مولى عليه فلا تتصور منه الولاية، والحضانة نوع منها واشترط المالكية[٣٥]

[1]واشترط المالكية[٣٥]

الشرط الثالث: الحرية.

فلا حضانة لرقيق ولا مبعضا وإن أذن له سيده عند جمهور الفقهاء الحنفية[٣٦] والشافعية[٣٧]والحنابلة[٣٨]

لأنها ولاية وليس من أهلها، ولأنه لا يوفي الحضانة حقها، إذ هو مشغول بخدمة سيده، ولا حظ للولد في حضانته بينما أجازه المالكية والشافعية في بعض الحالات [٣٩]وقال الظاهرية [٤٠]بجواز حضانة الرقيق مطلقا.

والراجح: قول الجمهور؛ لأنها ولاية فيصلح من كان أهلا لها دون غيره.

[2]

٣٤- البحر الائق لابن نجيم ج٤ ص١٧٩/ دار الكتاب الإسلامي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج٣ ص٧٥٨، الإقناع للشربيني الخطيب ج٢ ص٤٩١/ دار الفكر، البحر الزخار لابن المرتضى ج٤ ص٢٨٤/دار الكتاب الإسلامي، شرح النيل ج٧ ص٤٠٧ الل

٣٥- شرح مختصر خليل ج٤ ص٢١٢.

٣٦- المبسوط للسرخسي ج٥ ص٢١٣/ دار المعرفة.

الشرط الرابع:عدم القسوة.

وهذا الشرط نص عليه المالكية ، وقالو من علم منه قلة الحنان والعطف، إما لطبعه أو لعداوة بينه وبين أبوي المحضون قدم عليه غيره[٤١]

الشرط الخامس:صحة الجسم بالقدرة على القيام بشؤون المحضون.

فلا حضانة لمن لا قدرة له على صيانة الحضون كالمرأة المسنة[٤٢] والزمن، والأعمى، والأخرس، والأصم ولا لمن لم يكن سالما من الأمراض المعدية أو المنفرة كالجذام، والبرص، والحكة، والجرب، لما أجرى الله العادة من حصول مثل ذالك المرض المتصل بصاحبه[٤٣]

١

الشرط السادس: الأمانة.

٣٧- مغني المحتاج للشربيني الخطيب ج٥ ص١٩٥/ دار الكتب العلمية .

٣٨- مطالب أولي النهى ج٥ ص٦٦٧، الكافي في فقه الإمام أحمد ج٣ ص٢٤٥.

٣٩- كما لو إستلمت أم الكافر فإن ولدها يتبعها وحضانته لها مالم تنكح. مغني المحتاج ج٥ ص١٩٥، وجاء في شرح مختصر خليل ج٤ ص٢٠٨: قال مالك: وإذا أعتق ولد الأمة وزوجها حر فطلقها فهي أحق بحضانة ولدها.

٤٠- المحلى ج١٠ ص١٤٣.

٤١- شرح مختصر خليل ج٤ ص ٢١١، الفواكه الدواني ج٣ ص٦٧.

٤٢- البحر الرائق ج٤ ص١٧٩، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج٢ ص٧٥٨. شرح النيل ج٧ ص٤٠٧.

٤٣- التاج والإكليل ج٥ ص٥٩٧، الفواكه الدواني ج٢ ص٦٧. التاج المذهب ج٢ ص١٨٧/ مكتبة اليمن.

فلا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، لأن وجوده من لا يصونه كعدمه، فينتقل عنه إلى من يليه، وعليه فلا حضانة لغير أمين على تربية الصغير، كالفاسق أو المشهور بالفجور وفعل الحرام ؛ وذالك لأن الفاسق لا يولى ولا يؤتمن؛ ولأن المحضون لا حظ له في حضانتها؛ لأنه ينشأ على طريقتها(٤٤)

١

الشرط السابع: أمن المكان.

ويتحقق بأن يكون حرزا مصونا للمحضون ، بأن لا يخشى للبنت الفساد فيه، وكذا الذكر إن كان يخشى عليه الفساد أيضا.(٤٥)

٤٤- الفواكه الدواني ج٢ ص٦٧، أسنى المطالب ج٣ ص٤٤٨، نيل المآرب بشرح دليل الطالب لعبد القادر التغلبي ج٢ ص٣١١/ مكتبة الفلاح بالكويت/ الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م، كشاف القناع ج٥ ص٥٠٣.التاج المذهب ج٢ ص٢٦٩.

الشرط الثامن: الإقامة في وطن واحد.

فإن أراد الحاضن السفر، فلا يخلو السفر من أن يكون سفر نقله أو إنقطاع، أو لحاجة كتجارة وزيارة، ومن هنا فقد ذهب جمهور الفقهاء المالكية[٤٦] والشافعية[٤٧] والحنابلة[٤٨] إلى التفريق بينهما، فإن كان السفر للنقلة[٤٩]

١

٤٥- شرح مختصر الخليل ج٤ ص٢١١، الفواكه الدواتي ج٢ ص٦٧، شرح النيل ج٧ص ٤٠٧.

٤٦- شرح مختصر خليل ج٤ ص٢١٥، حاشية السوقي على الشرح الكبير ج٢ ص٥٣١.

٤٧- حاشيتا قليوبي وعميرة ج٤ ص٩٣. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية للأنصاري ج٣ ص٤٠٩.

٤٨- كشاف القناع للبهوتي ج٥ ص٥٠٠/ دار الكتب العلمية، الفتاوى الكبرى الابن تيمية ج٣ ص٦٤١/دار الكتب العلمية.

٤٩- واختلف الجمهور في تحديد مسافة السفر، فحددها المالكية بستة برد فأكثر على المعتمد، أو مسافة بريدين على قول، والأصح عند الشافعية لا فرق بين السفر الطويل والقصير، والصحيح من المذهب عند الحنابلة التحديد بمسافة القصر، وهو قول عند الشافعية، والبرد جمع بريد، والبريد: فرسخان، وقيل مابين كل منزلين بريد المحكم والمحيط الاعظم لابن سيدة ج٩ ص٣٢٣/ دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.

.

فإن حضانة الأم تسقط، وتنتقل لمن هو أولى بالحضانة بعدها بشرط أمن الطريق والبلد المقصود، والأب هو الأولى بالمحضون سواء اكان هو المقيم او المنتقل، لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير وحفظ نسبه فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، لكن قيد الحنابلة أولوية الأب بما إذا لم يرد مضارة الأم وإنتزاع الولد منها، فإذا أراد ذالك لم يجب إليه، بل يعمل ما فيه من مصلحة الولد. أما إذا سافرت الام مه الأب بقيت على حضانتها.

وإن كان السفر لحاجة كتجارة وزيارة كان الولد مع المقيم منهما حتى يعود المسافر، وتأخذه معها في سفرها لهذا الغرض عند المالكية، ويبقى معها إن سافر الأب.

أما الحنفية: [٥٠] فقد ذهبو إلى أنه ليس لزوج إن أراد الخروج من البلد، أن يأخذ ولده الصغير ممن له الحضانة من النساء حتى يستغني عنها، لأحقيتها يالحضانة منه.فلا يملك إنتزاعه من يدها، لما فيه من إبطال حقها، فضلا

عن الإخراج من البلد، وإن ارادت المرأت أن تخرج من المصر الذي فيه إلى غيره فللزوج أن يمنعها من الخروج سواء أكان معها ولد أو لم يكن؛ لأن عليها المقام في بيت زوجها، وكذالك إذا كانت معتدة لا يجوز لها الخروج مع الولد وبدونه، ولا يجوز للزوج إخراجها، لقوله عز وجل قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا

تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾

:(٥١)

أما إذا انت منقضية العدة فيجوز لها أن تنتقل بالمحضنون إلى بلد آخر بشرطين مجتمعين:الأول: أن يكوم البلد الذي تريد أن تنقل إليه الولد بلدها،

الثاني: ان يوقع النكاح فيه، فما لم يوجدا فيه مجتمعين لا يثبت لها ولاية النقل لأن المانع هو ضرر التفريق بينه وبين ولده وقد رضي به بالتزوج بها في بلدها،ولم يرض

١

ذالك في غير بلدها، ولم يكن النكاح في غير بلدها، دليلا على رضاه بالمقام فيه.

وقد علق ابن قيم الجوزي على أقوال الفقهاء السابقة فقال: وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه، فالصواب النظر والإحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له، وأصون أحفظ

٢

٥٠- بدائع الصنائع ج٤ ص٤٤ بتصرف، وأنظر أيضا الفتاوى الهندية ج١ ص٥٤٣

٥١- سورة الطلاق جزء من الآية رقم١.

روعى، ولا تأثير لأقامة ولا نقلة، هذا كله ما لم يرد لأحدهما بالنقل مضارة الآخر وانتزاع الولد منه. فإن اراد ذالك لم يجب إليه(٥٢)

الراجح:

أرى أن ما ذهب إليه إبن القيم الجوزي هو الراجح، إذ أن مصلحة المحضون أولى من مصلحة أحد أبويه عند التعارض؛ لأنه هو الأحوج إلى الصيانة والحفظ.

[١]المطلب الثاني: شروط الخاصة بالنساء.

الشرط الأول: أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من المحضون كأمه وأخته وجدته، وأن محرمة عليه، فإن كانت ذات رحم منه ولم تكن محرمة عليه، كبنت الخالة وبنت العمة وما أشبههما، لم يكن لها حق في الحضانة، وكذالك إن كانت محرمة عليه ولم تكن ذات رحم منه، كالمحرمة

عليه بالصهر والرضاع وما أشبههن لم يكن في الحضانة حق(٥٣)

الشرط الثاني: أن تكون خالية عن زوج أجنبي من المحضون.

فلا يوجد خلاف بين الفقهاء (٥٤)في عدم سقوط حق الحاضنة إذا تزوجت بذي رحم محرم من المحضون، كالأم إذا تزوجت بعم المحضون، وذالك لأن الزوج قائم مقام أبيه، ولأن كل واحد منهما له الحضانة منفردا، فمع إجتماعهما أولى فلا تصير مشغولا بهذا التزوج، إذ هي بمثابتها لو كانت خالية عن الزوجية،[٢]

٥٢- زاد الميعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية ج٥ ص٤١٤/ مؤسسة الرسالة بيروت، مكتبة المنار الإسلامية بالكويت/ الطبعة ١٤١٥/٢٧هـ-١٩٩٤م.

٥٣- المقدمات الممهدات ج١ ص٥٦٤، حاشية العدوي علي كفاية الطالب الرباني ج٢ ص١٣١/ دار الفكر، بيروت ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.

الشرط الثالث: أن لا تكون قد امتنعت من حضانته مجانا والأب معسر لا يستطيع دفع أجرة الحضانة، فإن كان الأب معسرا وقبلت قريبة أخرى تربيته مجانا ، سقط حق الأولى في الحضانة وهذا شرط عند الحنفية

الشرط الرابع: ألا تقيم الحاضنة بالصغير في بيت يبغضه ويكرهه، ولو مان قريبا له ، لأن سكانها مع المبغض يعرضه للأذى والضياع ، فلا حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها أم الطفل إذا تزوجت ، إلا إذا انفردت بالسكنى عنها . وهذا شرط عند المالكية، وشرط الشافعية والحنابلة أنه إذا كان المحضون رضيعا: أن ترضعه الحاضنة، فإن لم يكن لها لبن أو إمتنعت من الإرضاع، فلا حضانة لها ، لأن في تكليف الأب إستئجار مرضعه تترك منزلها وتنتقل إلي مسكن الحاضنة عسرا عليه، فلا يكلف ذالك.[١]

المطلب الثالث: شروط الخاصة بالرجال.

إذا كان الحاضن رجلا، فيشترط فيه شرطان.

الشرط الأول: أن يكون الحاضن محرما للمحضون إذا كان المحضون أنثى مشتهاة، وهي التي حدد الحنابلة والحنفية سنها بسبع سنوات، حذارا من الخلوة بها ، لإنفاء المحرمية بينهما، وإن لم تبلغ حد الشهوة أعطيت له بالإتفاق ، لأنه لا فتنه. فلا يكون إبن العم حضانة إبنة عمه المشتهات. واجاز

٥٤- المحيط البرهاني لابن مازة ج٣ ص١٧٨/ دار الكتب العلمية، الكافي في فقه الإمام أحمد ج٣ صجح٢٤٦.العناية ج٣ ص٣٧٠. شرح ميارة ج١ ص٢٧٣/ دار المعرفة، نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ج١٥ص٥٤٩/ دار المنهاج، العدة ج١ ص٤٧٨، شرح النيل ج٧ص٤١٠.

٥٥- موسوعة الفقه الإسلامي والقضيا المعاصرة للوهبة الزحيلي ج٨ ص ٦٧٩.

الحنفية إذا لم يكن للبنت عصبة غير إبن عمها إبقاءها عنده بأمر القاضي إذا كان مأمونا عليها، ولا يخشى عليها الفتنة منه(٥٥)

وكذالك أجاز الحنابلة تسليمها لغير محرم ثقة إذا تعذر غيره. وأجاز الشافعية تسليمها لغير محرم إن رافقته بنته او نحوها كأخته الثقة، وتسلم لها لا له، إن لم نتكن في رحله، كما لو كان في الحضر، أما لو كانت بنته أاو نحوها في رحله، فإنها تسلم إليه فتؤمن الخلوة.

الشرط الثاني: أن يكون عند الحاضن أب أو غيره من يصلح للحضانة من النساء كزوجة أو أم أو خالة أو عمة؛ إذ لا قدرة ولا صبر للرجال على أحوال الأطفال كما للنساء، فإن لم يكن عند الرجل من يحضن من النساء فلا حق له في الحضانة. وهذا شرط عند المالكية.

واشترط المالكية أيضا أن لا يسافر عن المحضون ولي المحضون أو تسافر الحاضنة سفر نقلة، ستة برد(٥٦) فاكثر، فإن اراد الولي أو الحاضنة السفر المذكور، كان له أخذ المحضون من حاضنته إلا أن تسافر معه، بشرط كون السفر لموضع مأمون وأمن الطريق، وهو شرط يقيد شروط الحضانة للنساء.[١]

٥٦) البريد العربي: ١٢ ميلا أو أربعة فراسخ، وتساوي ٢٢١٧٦ م والميل ١٨٤٨ م، والستة برد ١٣٣ كم.

المبحث الثالث: ترتيب درجات الحضانة، سقوط الحضانة، وفيه مطلبين.

المطلب الاول: ترتيب درجات مستحقي الحضانة.

قدم الفقهاء الحواضن بعضهن على بعض بحسب مصلحة المحضون، فجعلوا الإناث أليق بالحضانة؛ لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال، كما تقدم، ثم قدمو في الجنس الواحد من كان أشفق وأقرب، ثم الرجال العصبات المحارمن واختلفو احيانا في ترتيب الدرجات بحسب ملاحظة المصلحة، على النحو التالي علما بان مستحقي الحضانة إما إناث فقط، وإما ذكور فقط، وغما الفريقان، وذالك في سن معينة، فإذا إنتهت تلك السن كان الرجال أقدر على تربية الطفل من النساء [٥٧] [١]

أولا من النساء:

١- الأم أحق الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها، إلا أن تكون مرتدة او فاجرة فجورا يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة، أو غير مأمونة بان تخرج كل وقت، وتترك الولد ضائعا. ودليل تقديم الأم من الام من السنة: ما روى أن إمراة جاءت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم– فقالت له: يا رسول الله ، إن إبني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له

٥٧-البدائع: ٤/ ٤١-٤٤، الدرر المختار: ٢/ ٨٧١ وما بعدها ٨٧٧ وما بعدها، فتح القدير: ٣/٣١٣-٣١٧، الكتاب مع اللباب: ٣/١٠١-١٠٣، القوانين الفقهية: ص٢٢٤، الشرح الصغير: ٢/٧٥٦ وما بعدها، المهذب:٢/ ١٦٩-١٧١، مغني المحتاج: ٣/ ٤٥٢-٤٥٤، كشاف القناع: ٥/٥٧٦ وما بعدها، غاية المنتهى: ٣/٢٤٩، المغني: ٧/٦١٣، ٦١٩-٦٢٤.

حواء[٥٨] وإن اباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال: (أنت أحق به ما لم تنكحي)[٥٩]وقال صلي الله عليه وسلم: (من بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)[٦٠]

٢- ثم أم الأم (الجدة الأم) لمشاركتها الأم في الإرث والولادة، ثم عند الحنفية ، والشافعية في الجديد: أم الأب، لمشاركتها أم الأم في

المعنى السابق، [١]

ثم أم أبي الأب، ثم أم أبي الجد للمعنى نفسه. وأخر المالكية ام الاب بعد الخالة وعمة الأم.

وقدم الحنابلة الأب ثم أمهاته بعد الجدة لأم ، م الجدة ، ثم أمهاته.

٣- ثم الأخت عند الحنفية والشافعية والحنابلة – أخت المحضون الشقيقة، ثم عند الحنفية والحنابلة والمالكية الأخت لام، لأن الحق من قبلها، ثم الأخت لأب، وعكس الشافعية فقدمو في الأصح الاخت لاب على الأخت لأم، لاشتراكها مع المحضون في النسب، ولقوة إرثها، فإنها قد تصير عصبة، ثم بنات الأخت الشقيقة ثم لأم.

والسبب في تقديم الأخوات عند الجمهور هؤلاء على الخالات والعمات: انهن أقرب، وأنهن اولاد الابوين، لذا قدمن في الميراث.

وقدم المالكية الخالة، ثم الجدة لأب وإن علت ، ثم ابو المحضون على الأخت– أخت المحضون..

٤- ثم الخالة عند الحنفية والشافعية والحنابلة – خالة المحضون الشقيقة ، ثم عند الحنفية والحنابلة والمالكية خالة لأم، ثم خالة لأب لان الشان ان من كان من جهة الأم أشفق ممن كان من جهة الاب

٥٨- المكان الذي يضم الشيء ويجمعه.١

٥٩- رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه إسناده.

٦٠- رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي ايوب وهو صحيح.

فقط. والاصح عند الشافعية تقديم خالة لأب، وعمة لأب على من كان من جهة الأم، لققوة الجهة كالأخت.

وقدم المالكية كما سبق الخالة ثم الجدة لأب وإن علت على الأخت.[٦١][1]

٥- ثم بنات الأخت ، ثم بنات الاخ في راي الحنفية والشافعية، فالصحيح عندهم ان الخالة أولى من بنات الاخت او الأخ؛ لان بنت الأخ تدلي بقرابة الذكر، والخالة تدلي بقرابة الام، فكانت الخالة الأولى. وبنت الأخ اولى من العمة؛ لأن بنت الأخ أقرب، لأنها ولد الأب والعمة ولد الجد، فكانت بنت الأخ أقرب فكانت أولىن وذالك كما يقدم إبن الاخ في الميراث على العم. وراى المالكية والحنابلة ان العمة مقدمة على إبنة الأخ.

٦- ثم العمة إتفاقا – عمة المحضون ثم عمة أبيه وهي أخت جد المحضون.

والحاصل ان ترتيب الحواضن من النساء في المذاهب كما يأتي:

ا- الحنفية: الام، ثم أم الأم ثم ام الأب، ثم الأخوات ثم الخالات، ثم بنات الأخت ثم بنات الأخ، ثم العمات ثم العصبات بترتيب الإرث.

ب- المالكية:الأم ، ثم الجدة لأم ثم الخالة، ثم الجدة لأب وإن علت، ثم الأخت ثم العمة، ثم إبنة الأخ، ثم للوصي، ثم للأفضل من العصبة كما يأتي:

ج- الشافعية: الأم ، ثم أم الأم ، ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم الخالات، ثم بنات الأخ وبنات الاخت، ثم العمات، ثم لكل ذي محرم وارث من العصبات على ترتيب الإرث، فهم كالحنفية.

د- الحنابلة: الام، ثم ام الأم، ثم أم الأب، ثم الجد ثم أمهاته، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين، ثم لام ثم لاب، ثم عمة ثم خالة أم، ثم خالة أب ثم عمته، ثم بنت أخ، ثم بنت عم أب، ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب.

٦١- الموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة ج٨ ص- ٦٨٢

ثانيا _ من الرجال:

لا خلاف بين الفقهاء في استحقاق الأ للحضانة، إن لم يكن أحد من النساء، أو كن، لكن لسن أهلا لها، وإثبات هذا الحق للأب ، وإن لم يرد دليل يخصه، لكنه قد استفيد من قوله صلي الله عليه وسلم: (انت احق به ما لم تنكحي) فإن هذا يدل على ثبوت اصل الحق للأب بعد الأم ومن بمنزلتها.

وفيما يلي تفصيل الفقهاء في ترتيب المستحقين للحضانة من الرجال:

ا- الحنفية:

قالوا: إن لم يكن للمحضون أحد من النساء المذكورات، إنتقلت الحضانة إلى الرجال على ترتيب العصبات الوارثين المحارم: الآباء والأجداد وإن علو، ثم الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا، ثم الأعمام وأما بنو الأعمام فلا حق لهم في حضانة الصغيرة؛ لأن لهم رحما غير محرم، ويحل لهم نكاحها، فلا يؤمن عليها[٦٢]

ب- ويروون أن عصبته من الرجال يستوجبون الحضانة بمجرد التعصيب، كانوا من ذوي رحمه المحرم كالجد والعم والأخ وابن الأخ، أو من ذوي رحمه الذيليس بمحرم كابن العم وإن سفل، أو لم يكونوا من ذوي رحمه كالمولى المعتق.

[1]وأما أوصياؤه من الرجال والنساء، فإنهم يستوجبون الحضانة بمجرد الولاية، كانو مقدمين من قبل الأب أو من قبل السلطان.[٦٣]

ونصوا على أنه إن لم يكن من النساء، إنتقلت الحضانة إلى الوصي، ثم الأخ الشقيق، أو لأم، أو لأب، ثم للجد لأب، الأقرب فالأقرب، ثم إبن الأخ المحضون، ثم العم فإبنه[٦٤]

ج- الشافعية:

٦٢-المحيط البرهاني ج٣ ص١٧٨.

٦٣-المقدمات الممهدات ج١ ص٥٦٥.

٦٤- شرح مختصر خليل للخرشي ج٤ ص٢١٠،٢٠٩،

٦٥

-المهذب ج٣/ ١٦٦.

٦٦المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد للحرائي ج٢/ص١١٩.

قالوا: إجتمع الرجال وهم من أهل الحضانة، وليس معهم نساء قدم الأب، لأن له ولادة وفضل شفقة، ثم تنتقل إلى الآبائها الأقرب فالأقرب، لمشاركتهم الأب في الولادة والتعصيب، فإن عدم الأجداد تنتقل إلى من بعدهم من العصبلت،[٦٥]

د- الحنابلة:

أحق رجال الحضانة بها الأب، ثم الجد ثم أقرب العصبة[٦٦]

فللرجال من العصبلت حق في الحضانة، وأولاهم بالحضانة أولاهم بالميراث. فأما الرجال من ذوي الأرحام كالأخ من الأم، والخال وأبي الأم، والعم من الأم،، فلا حضانة لهم مع أحد من أهل الحضانة؛ لأنهم لا يحضنون بأنفسهم، وليس لهم قرابة قوية يستحقون بها، ولا حضانة لمن يدلي بهم من النساء، لأنه إذا لم يثبت حضانة، فمن أدلى بهم أولى، فإن عدم أهل الحضانة احتمل أن تنتقل إليهم، لأنهم يرثون عند عدم الوارث، فكذالك يحضنون عند عدم من يحضن، واحتمل أن لا يثبت لهم حضانة وتنتقل إلى الحاكم.

المطلب الثاني: سقوط الحضانة.

تسقط الحضانة بأربعة أسباب عند المالكية ، وافقهم في أغلبها غيرهم.

١- سفر الحاضن سفر نقلة وانقطاع إلى مكان بعيدة ، وهو مقدار ستة برد فأكثر، كما تقدم ، فلو سافر ولي المحضون أو سافرت الحاضنة ستة برد فأكثر لا أقل منها، فللولي أخذ المحضون، وتسقط حضانة الحاضنة إلا أن تسافر معه. وقال الحنفية: يسقط الحق في الحضانة إذا سافرت الأم المطلقة إلى بلد بعيد لا يستطيع فيه الأب زيارة ولده في نهار يرجع فيه إلى بيته ويبيت فيه، وأما غير الأم فتسقط حضانها بمجرد الإنتقال. وقال الشافعية: يسقط الحق بالحضانة بالسفر لمكان مخوف أو بقصد النقلة ، سواء أكان طويلا أم قصيرا.

وقال الحنابلة: يسقط الحق بالحضانة بالسفر لبلد يبعد بمقدار مسافة القصر فأكثر.

٢- ضرر في بدن الحاضن كالجنون والجذام والبرص، وافقهم فيه الحنابلة.

٣- الفسق أو قلة دينه من الحضانة ، بأن غير مأمون على الولد؛ لعدم تحقق المصلحة المقصودة من الحضانة، وهذا متفق عليه. وقد نصت المادة (١٤٧/٣) على أنه : إذا ثبت أن الولي – ولو أبا – غير مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية، وذالك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة. وأما نص الفقرة الأولى من هذه المادة فهو: إذا كان الولي غير الأب، فللقاضي وضع ولد ذكرا او أنثى عند الأصلح من الام او والولي أو من يقوم مقامها، حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد.

٤- تزوج الحاضنة ودخولها، إلا ان تكون جدة الطفل زوجا[٦٧] [١]

لجده أو تتزوج الأم عما له ، فلا تسقط؛ لأن الجد او العم محرم للصغير، وهذا كما تقدم. وكذا تسقط الحضانة عند الشافعية والحنابلة بالكفر، كما تسقط بالإتفاق بالجنون أو [٢]العته[٦٨].

المطلب الثالث: عودة الحق في الحضانة.

إذا سقطت الحضانة لمانع من الموانع:، ثم زال المانع ، فهل تعود الحضانة؟ للفقهاء فيه رأيان [٦٩]

قال المالكية في المشهور: إذا سقت حضانة الحاضنة لعذر كمرض وخوف مكان، وسفر ولي بالمحضون سفر نقلة، وسفرها لأداء فريضة الحج، ثم زال العذر بشفائها من المرض، وتحقق الأمن ،

٦٧-الموسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة ج٨ ص٦٩٠-٦٩١.

٦٨- القوانين الفقهية: ص٢٢٤ ، الشرح الصغير: ٢/ ٧٥٩ وما بعدها ، المقدمات الممهدات: ٥٦٩/١ وما بعدها، الدرر المختار ورد المحتار: ٢/ ٨٨٠. وما بعدها، المغني: ٦١/٧

٦٩- الدرر المختار ٢/ ٨٨٠، الشرح الصغير: ٧٦٣/٢، وما بعدها، مغني المحتاج: ٤٥٦/٣. كشاف القناع: ٥٨٠/٥

والعودة من السفر الاضطراري، عادت الحضانة إليها؛ لأن المانع من الحضانة هو العذر الإضطراري، وقد زال، وإذا زال المانع عاد الممنوع.

أما إن تزوجت الحاضنة بأجنبي غير محرم ودخل بها ، أو سافرت بإختيارها لا لعذر، ثم تأيمت بأن فارقها الزوج بطلاق أو فسخ نكاح أو وفاة، أو عادت من السفر الإختياري، فلا تعود إليها الحضانة بعد زوال المانع ؛ لأن سقوط الحضانة كان باختيارها، فلا تعذر.

وقال الجمهور (الحنفية واالشافعية والحنابلة): إذا سقطت الحضانة لمانع، ثم زال المانع عادت الحضانة إلى صاحبها، سواء أكان إضطراريا كالمرض، أم إختياريا كالزواج والسفر والفسق، لزوال المانع

لكن ذالك عند الحنفية في الحال بالنسبة للبائن ولو قبل إنقضاء العدة، أما الرجعية فلا بد من إنقضاء العدة فيها.

وذكر الشافعية أن المطلقة تستحق الحضانة في الحال قبل إنقضاء العدة على المذهب، بشرط رضا الزوج بدخول المحضون بيته إذا كان له، فإن لم يرض لم تستحق.

وقرر الحنابلة إستحقاق المطلقة الحضانة، ولو كان الطلاق رجعيا ، ولو لم تنقض العدة.

وقد نصت المادة (١٤١) من القانون السوري على أنه : يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.

المطلب الثاني: ثبوت الحضانة للعصبة، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: ثبوت الحضانة للأب

الأم أولى الناس بحضانة ولدها ذكرا كان أو أنثى متى كملت شرائط الحضانة فيها؛ لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي

له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال رسول الله ﷺ (**أنت أحق به ما لم تنكحي** (٧٠)[1]

ولأن الأم أقرب إليه، وأشفق عليه، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأة أبيه (٧١)[2].

(٧٠) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٠/١١) رقم ٦٧٠٧، وأبو داود في سننه (٦٩٣/١) في كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، رقم ٢٢٧٦، وعبد الرزاق في المصنف (١٥٣/٧) في كتاب الطلاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، رقم ١٢٥٩٦، والحاكم في المستدر (٢٢٥/٢) في كتاب الطلاق، والدراقطني في سننه (٣٠٤/٣) رقم ٢١٨، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/٨) في كتاب النفقات، باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد، كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحديث صححه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. والشيخ الألباني حسن ا لحديث؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر الإرواء (٢٤٤/٧) برقم ٢١٨٧.

(٧١) انظر المغني (٤١٣/١١-٤١٤).

واتفق العلماء على أن الأب تثبت له الحضانة لكنهم اختلفوا في درجته في الحضانة على قولين:

القول الأول: أن درجة الأب في الحضانة تأتي بعد القريبات من النساء، وهذا مذهب الحنفية والمالكية[٢٧] (٢٨)

القول الثاني: أن درجة الأب في الحضانة تأتي بعد الأم وأمهاتها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة[٧٤](١).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

أن النساء هن الأصل في باب القيام بحضانة القاصر، وإصلاح أمره والقيام بتغذيته؛ لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار، وإنما جاء الأب بعدهن مباشرة؛ لأن الحضانة لا تثبت إلا للعصبة، والأب أقوى العصبات[٧٥](٢).

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١. أن الأب أقرب إلى الطفل من غيره، وشفقته أكمل من غيره ممن بعده، فرجح بها على أمهاته ومن بعدهن[٧٦](٣).
٢. أن الجدات اللاتي من قبله إنما يدلين به، فلولاه لما كان لهن صلة بالطفل، فكان أحق بالحضانة منهن[٧٧](٤)، وإنما قدم الأم وأمهاتها عليه؛ لظاهر الحديث، وإلا فالأصل أن الحق له؛ إذ لا أقرب إلى الولد من أبيه؛ فإنه موهوب له، ومن كسبه كما هو منصوص في الأدلة النقلية.

---

(٧٤) انظر أسنى المطالب (٤٥٣/٣)، مغني المحتاج (٥٩٤/٣)، الإنصاف (٤٥٨/٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٢٤٩/٣).

(٧٥) انظر بدائع الصنائع (٤٥٦/٣، ٤٦٩-٤٧٠).

(٧٦) انظر كشاف القناع (٤٩٦/٥)، فقه الدليل (٣٨٩/٥).

(٧٧) انظر مغني المحتاج (٥٩٤/٣).

الترجيح:

الراجح . والله أعلم . هو القول الثاني القاضي بتقديم الأب على غيره من النساء إلا الأم وأمهاتها، وذلك لما يأتي:

الأول: لقوة أدلتهم.

الثاني: لأن تأخير الأب إلى الدرجة التي ذكرها الآخرون فيه هضم لحق الأبوة، وتأخير بدون موجب.

الثالث: أما ما ذكروه من تأخيره عن النساء بدعوى أن النساء هن الأصل في باب الحضانة، فيجاب عنها بما يلي:

١. عدم التسليم أن شفقة النساء تفوق شفقة الأب على أولاده، بل إنه لا يعدل شفقة الأب على أولاده إلا شفقة أمهم عليهم، وهذا عند التأمل مسلَّم عند الجميع.

٢. لأن تأخيره إلى هذه الدرجة مخالف لظاهر قوله ﷺ (**أنت أحق به ما لم تنكحي**)[(٧٨)(١)]، فإن المخاصمة كانت بين الأم وبين الأب، ولو كان الحق بعد الأم لأحد من قريبات الطفل لبينه النبي ﷺ بيانا شافيا، لاسيما في وقت الحاجة إلى ذلك البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز عند الجميع، فدل ذلك على أن الحق في الحضانة بعد الأم وأمهاتها للأب دون غيره.

الفرع الثاني: ثبوت الحضانة للجد

والمقصود بالجد هنا هو أبو الأب، وقد صرح العلماء بذلك إلا أن المالكية ذكروا وجها خلافا للمشهور من المذهب اختاره اللخمي وهو أن للجد الذي من قبل الأم له أحقية في الحضانة، ويأتي في المرتبة بعد الأخ والجد وبنيه والعم وبنيه[(٧٩)(٢)].

---

(٧٨) سبق تخريجه في ص (٦٦٣).

(٧٩) انظر جامع الأمهات (ص ٣٣٥)، الشرح الكبير (٥٢٨/٢)، شرح الخرشي (٢١٠/٤)، التاج والإكليل (٥٩٦/٥).

واتفقوا على أن الحضانة تثبت للجد أبي الأب، ولكنهم اختلفوا في درجته على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن العصبة من الرجال يأتون بعد القريبات من النساء، وأول العصبة الأب ثم الجد. وهذا مذهب الحنفية(٨٠)[١].

القول الثاني: أن درجة العصبة بعد قريبات الطفل من النساء، وأولهم الأخ، ثم الجد. وهذا مذهب المالكية(٨١)[٢].

القول الثالث: أن درجة الجد في الحضانة تأتي بعد الأم وأمهاتها، والأب وأمهاته، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة(٨٢)[٣].

(٨٠) انظر حاشية ابن عابدين (٥/٢٧١)، تبيين الحقائق (٣/٤٨).

(٨١) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/٥٢٨)، الشرح الصغير (٢/٧٥٧)، شرح الخرشي (٤/٢١٠).

(٨٢) انظر الحاوي الكبير (١١/٥١٨)، المهذب (٤/٦٤٧)، مغني المحتاج (٣/٥٩٤)، الإنصاف (٢٤/٤٥٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/٢٤٩).

الأدلة:

استدل الحنفية بما يلي:

أن النساء يقدمن في الحضانة لكونهن أشفق من الرجال، ثم يليهم العصبة من الرجال، والجد يكون بعد الأب؛ لأنه يقوم مقام الأب عند فقده(٨٣)[١].

واستدل المالكية بما يلي:

أن الأخ يجتمع مع المحضون في الصلب والبطن، أو في أحدهما، وشاركه في النسب، فلذا يقدم على الجد.

استدل الشافعية والحنابلة بما يلي:

أن الجد يأخذ حكم الأب عند فقده، وإنما قدمت أم الأب على الجد؛ لأن جانب الأمهات في معرفة الحضانة أقوى، لذا قدمت عليه(٨٤)[٢].

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وذلك لما يأتي:

أولا: لقوة دليلهم.

ثانيا: لأن الحضانة نوع من الولاية، والجد له القدرة على تولي هذه الولاية إذا فقد الأب كسائر الولايات.

(٨٣) انظر حاشية ابن عابدين (٥/٢٧١).

(٨٤) انظر المهذب (٤/٦٤٧)، البيان (١١/٢٨٥)، كشاف القناع (٥/٤٩٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/٢٤٩)، مطالب أولى النهى (٥/٦٦٦).

ثالثا: ما ذكروه من تقديم بعض النسوة عليه في الحضانة؛ لكونهن أشفق، يجاب عنها بأن الجد أب، ويقوم مقامه عند فقد الأب، وشفقته أكمل من هؤلاء النسوة. والأب أحق بالحضانة بعد الأم وأمهاتها، وكذا الجد يكون أحق بعد أم الأب؛ لكونها تساويه في الدرجة، والأنوثة أصل في باب الحضانة.

الفرع الثالث: ثبوت الحضانة لسائر العصبة

ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن الحضانة تثبت لسائر العصبة كما تثبت للأب والجد، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والصحيح من مذهب الشافعية(٨٥)[١].

استدلوا بما يلي:

أولا: أن ابنة حمزة تبعت المسلمين في خروجهم من مكة بعد عمرة القضاء، وهي تقول: يا عم، فتناولها علي ﷺ، فأخذها بيدها. فاختصم فيها علي، وجعفر، وزيد. فقال علي: ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي ﷺ لخالتها، وقال: (**الخالة بمنزلة الأم**)(٨٦)[٢]

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ أقر على علي وجعفر رضي الله عنهما ادعاءهما للحضانة، ولو لم يكونا من أهل الحضانة لأنكر عليهما، فدل ذلك ثبوت الحضانة للعصبة(٨٧)[٣].

ثانيا: لأن لهم ولاية، وتعصيبا بالقرابة يمتازون بها، فثبتت لهم الحضانة كالأب والج) [٤].

ثالثا: لأن مناط الحضانة الشفقة، وهي متوفرة في العصبات النسبية(٨٨)[٥].

وذهب الشافعية في وجه عندهم إلى أنه لا حضانة لغير الآباء والأجداد من العصبات(٨٩)[٦].

---

(٨٥) انظر بدائع الصنائع (٣/٤٦٠)، حاشية ابن عابدين (٥/٢٧٠)، الشرح الكبير (٢/٥٢٨)، المهذب (٤/٦٤٥)، البيان (١١/٢٨١)، فتح العزيز (١٠/١٠٤)، المغني (١١/٤٢٥).

(٨٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٢/٩٦٠) في كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان، وفلان وإن لم ينسب إلى قبيلته أو نسبه، رقم ٢٥٥٢.

(٨٧) انظر المهذب (٤/٦٤٥)، المغني (١١/٤٢٥).

(٨٨) انظر المهذب (٤/٦٤٥)، البيان (١١/٢٨١)، المغني (١١/٤٢٥).

(٨٩) انظر فتح العزيز (١٠/١٠٤).

(٩٠) انظر المهذب (٤/٦٤٥)، البيان (١١/٢٨٠-٢٨١)، روضة الطالبين (٩/١١٠).

استدلوا بما يلي:

١. لأن العصبات غير الأب والجد لا معرفة لهم في الحضانة[٩٠][١].

٢. لأنه لا ولاية لهم في مال المحضون بأنفسهم، فلم تكن لهم حق الحضانة كالأجانب[٩١][٢].

الترجيح:

الراجح . والله أعلم هو قول الجمهور، وذلك لما يأتي:

أولا: لقوة دليلهم.

ثانيا: وما ذكر في الوجه الثاني من مذهب الشافعية يجاب عنه بما يلي:

١. أما قولهم لا معرفة لهم في الحضانة، فيجاب عنه بأنه غير مسلم؛ لأن الحضانة مناطها الشفقة، وهي موجودة في العصبة.

٢. أما القياس على الأجانب بجامع عدم الولاية في مال المحضون، فيجاب عنه بأنه قياس مع الفارق، والفرق من وجهين:

الأول: لأن الأجانب ليس لهم ولاية ولا شفقة بخلاف العصبة فإن لهم شفقة، ولهم الولاية في المال أيضا إذا لم يكن هناك من هو أولى منهم فيه.

الثاني: لأن الأجانب تساووا في عدم القرابة، فليس واحد منهم أولى بالآخر، والعصبات لهم قرابة يمتازون بها، واختيارهم في الحضانة يكون بحسب قربهم من المحضون إذا توفرت الشروط المذكورة سابق[٩٣][٣].

وإذا ثبتت الحضانة للعصبة النسبية فترتيبهم يكون كالآتي:

أولا: عند الجمهور:

---

(٩١) انظر المهذب (٤/٦٤٥)، البيان (١١/٢٨٠-٢٨١)، المغني (١١/٤٢٤).

(٩٢) انظر المصدرين السابقين.

(٩٣) انظر المغني (١١/٤٢٥).

الأب ثم جد أبو الأب وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ من الأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم الشقيق ثم العم من الأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم من الأب، وهكذا(٩٤)(١).

ثانيا: المالكية:

الأب ثم الوصي ثم الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم، وهكذا(٩٥)(٢).

والفرق بين الجمهور والمالكية هو تقديم الأخ على الجد عند المالكية، والصحيح أن الجد يقدم على الأخ؛ لكون الجد يقوم مقام الأب عند فقده، والله أعلم.

(٩٤) انظر بدائع الصنائع (٣/٤٦٠)، البيان (١١/٢٨١)، المغني (١١/٤٢٤).

(٩٥) انظر حاشية الدسوقي (٢/٥٢٧-٥٢٨)، بلغة السالك (٢/٧٥٦-٧٥٧).

المطلب الثالث: اجتماع العصبة مع غيرهم، وفيه سبعة فروع:

الفرع الأول: اجتماع الأب والجدة أم الأب[٩٦][١].

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا اجتمع الأب، وأم نفسه أيهما أولى بأحقية حضانة المحضون، على قولين:

القول الأول: أن أم الأب مقدمة على الأب في أحقية الحضانة، وهذا مذهب المالكية والظاهرية[٩٧][٢].

القول الثاني: أن الأب مقدم على أم نفسه في أحقية الحضانة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة[٩٨][٣].

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

أن الأصل في باب الحضانة هن النساء؛ لأنهن أشفق وأرحم وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار ورعاية شئونهن، فلذا تقدم أم الأب على الأب[٩٩][٤].

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

أن أم الأب تدلي إلى المحضون بواسطة الأب، فيكون الأب مقدم عليها في أحقية الحضانة؛ لأن المدلى به أحق من المدلي[١٠٠][١].

---

(٩٦) وهذا الخلاف لا يتأتى على مذهب الحنفية؛ فإنهم كما سبق أن درجة العصبة تكون بعد القريبات من النساء، وليس لهم أي تزاحم مع النساء في باب الحضانة. انظر ص ٦٦٤.

(٩٧) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٢٧/٢)، بلغة السالك (٧٥٦/٢)، شرح الخرشي (٢٠٩/٤)، الفواكه الدواني (١٠٣/٢)، المحلى (٣٢٣/١٠).

(٩٨) انظر مختصر المزني مع الحاوي الكبير (٥١٧/١١)، المهذب (٦٤٦/٤)، مغني المحتاج (٥٩٤/٣)، المغني (٤٢٦/١١)، الإنصاف (٤٥٨/٢٤).

(٩٩) انظر بدائع الصنائع (٤٥٦/٣)، شرح الخرشي (٢٠٨/٤).

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول بتقديم الأب على الجدة؛ لقوة تعليل من قال بهذا القول.

الفرع الثاني: اجتماع الأب مع الخالة:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اجتماع الأب مع الخالة أيهما أحق بالحضانة، على قولين:

القول الأول: أن الأب أولى بالحضانة من الخالة، وهذا هو المعتمد عند الشافعية، والرواية المشهورة عند الحنابلة[١٠١][٢].

القول الثاني: أن الخالة مقدمة على الأب في أحقية الحضانة، وهذا مذهب المالكية، وهو وجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة[١٠٢][٣].

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١. أن الأب له ولادة ومن العصبة النسبية، ووارث، فيقدم على الخالة كالأم[١٠٣][٤].

٢. لأن للأب فضل الحنو والشفقة لما ليس لغيره عدا الأم[١٠٤][٥].

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١. لأن النساء هن أصل في باب الحضانة ورعاية الطفل والمعرفة بأحواله، وهن أشفق من غيرهن،

---

(١٠٠) انظر مغني المحتاج (٥٩٤/٣)، المغني (٤٢٦/١١)، الشرح الكبير (٤٥٨/٢٤).

(١٠١) انظر مختصر المزني مع الحاوي الكبير (٥١٧/١١)، المهذب (٦٤٦/٤)، فتح العزيز (١٠٧/١٠)، المغني (٤٢٦/١١).

(١٠٢) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٢٧/٢)، شرح الخرشي (٢٠٩/٤)، المهذب (٦٤٦/٤)، البيان (٢٨٣/١١)، روضة الطالبين (١١٢/٩)، المغني (٤٢٦/١١)، الإنصاف (٤٥٩/٢٤).

(١٠٣) انظر الحاوي الكبير (٥١٩/١١)، المهذب (٦٤٦/٤) فتح العزيز (١٠٧/١٠).

(١٠٤) انظر الحاوي الكبير (٥١٩/١١).

لذا تقدم الحالة على الأب[١٠٥][(١)].

٢. لأن الخالة تدلي بالأم؛ لأنها أختها فتقدم على الأب في الحضانة كأم الأم[١٠٦][(٢)].

الترجيح:

الراجح . والله أعلم . هو القول بتقديم الأب على الخالة، وذلك لما يأتي:

أولا: لقوة تعليل من قال بهذا القول

ثانيا: قوله ﷺ (**أنت أحق به ما لم تنكحي**) يدل على أن الأب يكون أحق بعد الأم إذا نكحت، فلو كانت الخالة أو غيرها أحق بحضانة الطفل لبين النبي ﷺ للأمة حتى يكون حكما عاما، وحسما للخلاف.

ثالثا: أما ما ذكره أصحاب القول الآخر من التعليلات فيجاب عنها بما يلي:

١. ما ذكروه من زيادة الشفقة عند الخالة غير مسلم، فإن الأب أكثر شفقة لولده بعد أمه؛ لأن الولد جزء منه، ومن كان هذا حاله يكون الشفقة منه أكثر.

٢. قولهم بأن الخالة تدلي بالأم لذا تقدم على الأب، يجاب عنه بأن الولد جزء من أبيه ويدلي به بدون واسطة، فيقدم على من يدلي إليه بواسطة.

٣. أما القياس على أم الأم فيجاب بالفرق بأن أم الأم تقوم مقام الأم عند فقد الأم في بعض الأحكام خلافا للخالة.

---

(١٠٥) انظر شرح الخرشي (٢٠٨/٤)، البيان (٢٨٣/١١)، فتح العزيز (١٠٧/١٠).

(١٠٦) انظر المهذب (٣٤٦/٤)، البيان (٢٨٣/١١).

الفرع الثالث: التخيير بين العصبة والأم في الحضانة

سبق في الفرع السابق أن ولاية الحضانة والضم تثبت للعصبة النسبية بالشروط المذكورة سابقا.

وعند ما تنتهي حضانة الأم لليتيم أو اليتيمة، هل يخير أحدهما في البقاء مع الأم أو إلى الانضمام إلى من له ولاية الضم من عصبته، وما هي شروط التخيير عند من يقول بالتخيير؟

المسألة الأولى: تخيير الطفل المميز أو الطفلة المميزة إذا انتهت حضانة أمه بينها وبين عصبته

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن الأم أحق باليتيم حتى يستغني عنها، ثم يضمه الولي العاصب، ولا خيار له. وأما اليتيمة فالفتوى عندهم(١٠٧)[١] أن الأم وغيرها من الحواضن أحق بها حتى تشتهى، ثم تضم بعد ذلك إلى عصبتها المحرم، ولا خيار لها أيضا(١٠٨)[٢].

القول الثاني: لا خيار لليتيم أو اليتيمة بل يكونان في حضانة الأم أو من يقوم مقامها حتى يبلغ اليتيم، وتبلغ اليتيمة. واليتيمة بعد بلوغها تكون عند أمها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها(١٠٩)[٣]. هذا إذا كانت الأم أو من يقوم مقامها مأمونا وفي حرز ومنعة وتحصين. فإن خيف على اليتيمة بعد البلوغ في المقام مع الأم أو من يقوم مقامها، ضمت إلى عصبتها، وهذا مذهب المالكية(١١٠)[٤].

---

(١٠٧) والفتوى عندهم خلاف ظاهر الرواية، وظاهر الرواية عندهم أن الأم أحق بها ما لم تحيض. انظر المبسوط (٢١٢/٥)، بدائع الصنائع (٤٥٩/٣)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١٠٩/٢).

(١٠٨) انظر بدائع الصنائع (٤٥٩/٣)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١٠٨/٢-١٠٩)، الفتاوى الهندية (٢٦٧/١)، حاشية ابن عابدين (٢٧٠/٥).

(١٠٩) لأن الحضانة عندهم بالنسبة للأنثى كالنفقة. انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٢٦/٢)، مواهب الجليل (٢١٤/٤).

(١١٠) انظر المدونة (٢٥٨/٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٢٦/٢)، مواهب الجليل من أدلة الخليل للشنقيطي (٢٤٥/٣).

القول الثالث: أن اليتيم يخير بين أمه وبين عصبته إذا بلغ سن التمييز، ويكون عند من اختار منهما، وإذا لم يختر أحدهما أقرع بينها ويكون عند من تخرج له القرعة[١١١][١]. وكذلك اليتيمة إلا أنها لا تخير عند العصبة غير المحرم، بل تبقى عند أمها أو من يقوم مقامها من الحاضنات، وهذا مذهب الشافعية[١١٢][٢].

القول الرابع: أن اليتيم إذا بلغ سن السابع يخير بين أمه وعصبته فيكون مع من يختار من الأم أو من العصبة. وأما اليتيمة فلا تخير عند السبع، بل تضم إلى عصبتها المحرم. وإذا اختارهما أو لم يختر أحد منهما، أقرع بينهما، وهذا مذهب الحنابلة[١١٣][٣].

يظهر من الاستعراض السابق للمذاهب أن العلماء اختلفوا في التخيير على قولين.

الشافعية والحنابلة يثبتون التخيير، والحنفية والمالكية ينفونه.

---

(١١١) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، ولا يمكن اجتماعهما على حضانته، فيقدم أحدهما بالقرعة؛ لأن الحقوق إذا تزاحمت ولم يوجد ثمّ مرجح، يلجأ إلى الاقتراع للترجيح. انظر المهذب (٦٤٩/٤)، الشرح الكبير (٤٨٨/٢٤).

(١١٢) والتفريع هنا على المعتمد عندهم كما مر في الفرع الثالث من المطلب الثاني. انظر مختصر المزني مع الحاوي الكبير (٥٢٢/١١)، المهذب (٦٥١/٤)، البيان (٢٩٠/١١)، فتح العزيز (٩٦/١٠)، روضة الطالبين (١٠٤/٩).

(١١٣) انظر الإرشاد (ص ٣٢٧)، المغني (٤١٧/١١، ٤١٨)، الإنصاف (٤٨٣/٢٤، ٤٩٠)، كشاف القناع (٥٠١/٥-٥٠٣)، فقه الدليل (٣٩٤/٥، ٣٩٦).

الأدلة:

استدل الحنفية بما يلي:

١. أن الصبي بطبعه يميل إلى اللهو واللعب واختيار اللذة الحاضرة من الكسل، وعدم الاهتمام بالتعليم الجاد، فإذا قيل بالتخيير فيختار ما يوافق هواه من الإهمال وغير ذلك مما يحب، ولذا فالتخيير ليس مناسبا به(١١٤)[١].

٢. لأن غير البالغ ليس برشيد، ولا يعرف مصلحته، فلا يعتبر اختياره كسائر تصرفاته(١١٥)[٢].

استدل المالكية بما يلي:

١. لأن الغلام لا قول، ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلعب عنده، ويترك تأديبه، ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده(١١٦) [٣].

٢. بحديث (**أنت أحق به ما لم تنكحي**)(١١٧)[٤].

وجه الدلالة: أن القول بالتخيير يبطل معنى الحديث؛ لأنه لو خير الطفل لم تكن الأم هي أحق به، إلا إذا اختارها، والنبي ﷺ جعلها أحق به مطلقا عند المخاصمة إلا في حالة تتلبس بالزواج(١١٨)[٥].

استدل الشافعية بما يلي:

١. لأن النبي ﷺ خير علاما بين أمه وأبيه(١١٩)[٦].

---

(١١٤) انظر بدائع الصنائع (٣/٤٦١).

(١١٥) انظر المغني (١١/٤١٥).

(١١٦) مواهب الجليل من أدلة الخليل (٣/٢٤٥).

(١١٧) سبق تخريجه في ص (٦٦٣)

(١١٨) انظر زاد المعاد (٥/٤٢٥).

(١١٩) سبق تخريج الحديث في تخيير النبي ﷺ بين الأم الكافرة والأب المسلم، في ص (٦٦١).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ فعل التخيير بين الأم والأب، وكذلك تثبت التخيير للعصبة؛ لأن الأب من العصبة.

٢. ما رواه عمارة الجرمي أنه قال غزا أبي نحو البحر في بعض تلك الغزوات، قال: فقتل، فجاء عمي ليذهب بي، فخاصمته أمي إلى علي رضي الله عنه ، فخيرني علي رضي الله عنه ثلاثا، فخيرت أمي، فأبى عمي أن يرضى، فوكزه علي بيده وضربه بدرته، وقال: وهذا أيضا لو بلغ خير[١٢٠](١).

٣. لأن اليتيمة كاليتيم في التخيير، وكون الأحاديث واردة في الغلام لا تأثير له في الحكم؛ لأن القصد بالضم والحضانة الحظ والنفع للولد ذكرا كان أم أنثى، وبالتمييز صار عارفا بحظه ومصلحته ونفعه، فيرجع إلى التخيير بالنسبة للغلام والغلامة[١٢١](٢).

استدل الحنابلة بما يلي:

١. بالحديث الذي استدل به الشافعية، وجعل الحنابلة هذا الحديث خاصا في اليتيم دون اليتيمة؛ لأن الأنثى تخالف الذكر، فلا تقاس عليه؛ لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة، والرجال أولى بذلك. ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج، وإنما تخطب من وليها، فينبغي أن يقدم على غيره[١٢٢](٣).

٢. لأن التقديم في الحضانة لحق الولد، فيقدم من هو أشفق؛ لأن حظ الولد عنده أكثر، واعتبر الشفقة بمظنتها؛ إذ لم يمكن اعتبارها بنفسها. فإذا بلغ الغلام حدا يعرب عن نفسه، ويميز بين الإكرام وضده، فمال أحد الخيارين دل على أنه أرفق به وأشفق عليه، فيقدم بذلك[١٢٣](٤).

---

(١٢٠) أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف (١٨٠/٤) في كتاب الطلاق، باب ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد، رقم ١٩١٢٧، وعبد الرزاق في المصنف (١٥٦/٧) في كتاب الطلاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، رقم ١٢٦٠٩، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/٨) في كتاب النفقات، باب الأم أحق بولدها ما لم تتزوج كلهم من طريق عمار الجرمي. والحديث ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (٢٥٠/٧-٢٥١) رقم ٢١٩٥).

(١٢١) انظر مغني المحتاج (٥٩٨/٣)، تحفة المحتاج (٢٦٠/٨)، نهاية المحتاج (٢٣١/٧).

(١٢٢) انظر المغني (٤١٨/١١)، كشاف القناع (٥٠٢/٥).

(١٢٣) انظر المغني (٤١٦/١١)، الشرح الكبير (٤٨٥/٢٤).

٣. ولأن هذا القريب عاصب، فأشبه الأب[١٢٤][(١)].

(١٢٤) انظر المعني (٤١٧/١١)، الشرح الكبير (٤٨٩/٢٤).

الترجيح:

الراجح . والله أعلم . هو القول القاضي بتخيير اليتيم دون اليتيمة[١٢٥][(١)]، وذلك لما يأتي:

أولا: لأن الأحاديث والآثار وردت في تخيير اليتيم، واليتيمة تخالفه، لما ذكره الحنابلة من الفروق بينهما، ولذا لا يصح قياسها عليه.

وهذا إذا كان العاصب قادرا على حفظها وصيانتها ورعايتها على الوجه المطلوب شرعا. فأما إذا كان مهملا لها، ولا يأبه برعايتها، أو كان عاجزا عن ذلك، أو كان غير مرضي في أخلاقه ودينه، ولا غيرة عنده تجاه موليته، فالأم أحق بها منه؛ لأن الحضانة تعتمد على الشفقة والتربية والملاطفة والصيانة والحفظ، فأحق الأقارب بها أقومهم بهذه الصفات[١٢٦][(٢)].

ثانيا: ما ذكره الآخرون من الأدلة والتعليل يجاب عنها بما يلي:

١. أما قول الحنفية إن تخيير الغلام ليس بحكمة؛ لكونه تغلبه هواه ويميل إلى اللذة ويختارها، فيجاب عنه بأن الأحاديث أثبت التخيير في باب الحضانة، فلا يرد ذلك بأمور مظنونة[١٢٧][(٣)]. ولأن المقصود بالحضانة التربية والحفظ والرعاية والشفقة، فيقدم من هو أشفق، فإذا بلغ الصبي حدا يعبر عن نفسه ومال إلى أحد الأقارب دل إلى أنه أرفق وأشفق عليه فيقدم على غيره.
٢. قولهم بأن اليتيم لا يعرف مصلحته لكونه غير رشيد، فلا يعتبر اختياره، يجاب عنه بأن من تصرفات الصبي ما هو معتبر، وهي ما يكون لمصلحته المحضة، وكونه عند من هو أكثر شفقة محض مصلحة له. ولأن القصد من الضم الحفظ للولد، والمميز أعرف بحظه، فيرجع إليه.
٣. وأما استدلال المالكية بالحديث (**أنت أحق به ما لم تنكحي**) فيجاب عنه بأن الحديث لا يدل على بطلان التخيير؛ لأنه حديث مطلق يدل على أن الأم أولى بولدها من أبيه ما لم تنكح، فيقيد بأحاديث

(١٢٥) وهو المشهور عند المذهب الحنبلي، والمفتى عند الحنفية فيما يتعلق باليتيمة.
(١٢٦) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٤/١٢٣-١٢٨).
(١٢٧) انظر مواهب الجليل من أدلة الخليل (٣/٢٤٥).

التخيير جمعا بين الأحاديث، فتكون أحق به ما دام دون التمييز أو إذا اختارها بعد التمييز.

المسألة الثانية: شروط التخيير عند من يقول بالتخيير:

الشافعية والحنابلة الذين قالوا بالتخيير قيدوا ذلك بشروط ثلاثة:

الأول: أن يكون الطرفان المتخاصمان في الحضانة من أهلها، فإن كان أحدهما من غير أهلها بأن كان فاجرا أو معتوها أو مجنونا أو عاجزا عن القيام بمهمة الحضانة فيعتبر كالمعدوم ويستحقها الآخر.

الثاني: أن لا يكون المحضون والمكفول معتوها، أو ناقص العقل، فإن كان معتوها كان عند الأم ولم يحصل التخيير بينها وبين غيرها؛ لأن المعتوه وناقص العقل يعتبر كالطفل غير المميز وإن كان كبيرا.

الثالث: السلامة من الفساد، فإن علم أن الطفل المميز يختار أحد الأقارب ليمكنه من الفساد، ويفتح له الباب مصراعيه لملذاته وشهواته التي لا تساعده على التقدم في العلم والأدب، وأنه لا يختار الآخر لكونه يكرهه على الأدب واكتساب الرجولة والشهامة، لم يعمل بمقتضى شهوته؛ لأن ذلك إضاعة[١٢٨][1].

الفرع الرابع: اجتماع الأخت لغير أم مع الأخت من الأم

اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الأخت من الأبوين تقدم على الأخت من الأم في أحقية الحضانة؛ لقوة قرابتها؛ لأنه أدلت إلى المحضون بأصلين[١٢٩][2].

واختلفوا فيما إذا اجتمعت الأخت من الأب والأخت من الأم أيهما أحق بالحضانة إلى قولين:

---

(١٢٨) انظر فتح العزيز (٩٥/١٠)، المجموع المذهب في قواعد المذهب (٤٦٠/٢-٤٦٢)، مغني المحتاج (٥٩٨/٣)، المغني (٤١٧/١١)، مطالب أولى النهى (٦٦٧/٥).

(١٢٩) انظر بدائع الصنائع (٤٥٧/٣)، حاشية ابن عابدين (٢٦٣/٥)، التاج والإكليل (٥٩٦/٥)، شرح الخرشي (٢٠٧/٤)، مختصر المزني مع الحاوي (٥١١/١١)، المهذب (٦٤٤/٤)، فتح العزيز (١٠٢/١٠)، المغني (٤٢٣/١١)، الإنصاف (٤٦٠/٢٤)، كشاف القناع (٤٩٧/٥).

القول الأول: أن الأخت من الأب مقدمة على الأخت من جهة الأم، وهذا هو المذهب عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد شهرها بعض أصحابه[١٣٠][(١)].

القول الثاني: أن الأخت من جهة الأم تقدم على الأخت من جهة الأب، وهذا هو مذهب الحنفية، والمالكية، ووجه عند الشافعية اختاره المزني، ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب عند الحنابلة كما صرح بذلك صاحب الإنصاف[١٣١][(٢)].

(١٣٠) انظر مختصر المزني مع الحاوي الكبير (٥١١/١١)، المهذب (٦٤٤/٤)، روضة الطالبين (١٠٩/٩)، المغني (٤٢٣/١١)، الإنصاف (٤٦١/٢٤).

(١٣١) انظر بدائع الصنائع (٤٥٧/٣)، حاشية ابن عابدين (٢٦٣/٥)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١٠٧/٢)، شرح الخرشي (٢٠٩/٤)، منح الجليل (٤٢٢/٤)، الحاوي الكبير (٥١٤/١١)، الإنصاف (٤٦١/٢٤)، كشاف القناع (٤٩٧/٥).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١. لأن الأخت من الأب أقوى في الميراث من الأخت من جهة الأم، كالأخت من الأبوين[١٣٢][١].

٢. لأنها أقيمت مقام الأخت من الأبوين عند عدمها، وتكون عصبة مع البنات[١٣٣][٢].

٣. لأن الأخت من الأم تحجب بفرع الوارث الأنثى، وبالجد، بخلاف الأخت من الأب فإنها لا تحجب بهن بل تصير عصبة مع الغير، وتقاسم الجد عند الجمهور[١٣٤][٣].

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

أن الأم أصل في باب الحضانة والأخت من الأم أدلت بها، والمدلي بالأم أحق من المدلى بالأب كالجدات[١٣٥][٤].

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول بتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم، وذلك لم يأتي:

أولا: لقوة أدلتهم.

ثانيا: لأن أصول الشرع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب على أقارب الأم، وذلك في الميراث وولاية النكاح وغير ذلك، ولم يعهد من الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام، فمن قدمها في الحضانة، فقد خالف أصول الشريعة، وخرج عن موجب الدليل[١٣٦][١].

---

(١٣٢) انظر الحاوي الكبير (٥١٤/١١)، المغني (٤٢٣/١١)، الشرح الكبير (٤٥٩/٢٤).

(١٣٣) انظر الحاوي الكبير (٥١٤/١١)، المغني (٤٢٣/١١).

(١٣٤) انظر المغني (٤٢٣/١١).

(١٣٥) انظر بدائع الصنائع (٤٥٧/٣)، حاشية ابن عابدين (٢٦٣/٥)، الحاوي الكبير (٥١٤/١١)، المهذب (٦٤٤/٤)، فتح العزيز (١٠٢/١٠)، المغني (٤٢٣/١١)، كشاف القناع (٤٩٧/٥).

ثالثا: ما ذكروه من اعتبار إدلاء الأخت من الأم بالأم يجاب عنه بأن القوة بالميراث صفة في نفسها، فكان أولى في الترجيح من اعتبار صفة من غيرها[١٣٧][٢].

الفرع الخامس: إسقاط الأم حقها في الحضانة

عرفنا فيما مضى أن الأم هي أحق الناس بحضانة ولدها إذا توفرت فيها شروط الحضانة، ذكرا كان الولد أو أنثى، ولم يقم بالمحضون وصف يقتضي تخييره بين الأم وغيرها من العصبة أو ضمه إلى ولية.

واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما إذا أسقطت الأم حقها في حضانة ولدها، أو امتنعت أو لم تكن أهلا للحضانة، هل تنتقل إلى من يليها في الحضانة من النساء أو لا تنتقل، على قولين:

القول الأول: أن حق الحضانة ينتقل إلى أمهاتها اللائي كن بعدها في الدرجة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والمعتمد عند الشافعية والأصح عند الحنابلة[١٣٨][٣].

القول الثاني: أن حق الحضانة لا ينتقل إلى أمهاتها بل ينتقل إلى الأب إذا أسقطت الأم حقها في الحضانة أو امتنعت، وهذا وجه عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة[١٣٩][١٤٠][٤][٥].

---

(١٣٦) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٢٣/٣٤ وما بعدها، زاد المعاد (٣٩٣/٥).

(١٣٧) انظر الحاوي الكبير (٥١٤/١١)، المغني (٤٢٣/١١).

(١٣٨) انظر حاشية ابن عابدين (٢٦٣/٥)، روضة الطالبين (١٠١/٩)، المغني (٤٢٧/١١)، الإنصاف (٤٦٦/٢٤)، كشاف القناع (٤٩٨/٥).

(١٣٩) انظر روضة الطالبين (١٠١/٩)، المغني (٤٢٧/١١)، الإنصاف (٤٦٦/٢٤).

(١٤٠) وهناك وجه ثالث عند الشافعية بأنها تنتقل إلى السلطان قياسا على عضل الولي لإنكاح المرأة. انظر روضة الطالبين (١٠١/٩).

الأدلة:

استدل الجمهور بما يلي:

١. لأن الأب أبعد، فلا تنتقل إليه مع وجود أقرب منه[١٤١](١).

٢. لأن الأم امتنعت عن الحضانة فتنتقل إلى أمهاتها كما لو ماتت أو ارتدت[١٤٢](٢).

٣. لأن حق القريب سقط حقه لمعنى اختص به، فاختص السقوط به، كما لو سقط لمانع[١٤٣](٣).

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١. لأن أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق، فإذا أسقطت حقها، سقط حق فروعها[١٤٤](٤).

٢. لأن حق الأم من الحضانة لم يبطل بإسقاطها، بدليل لو طالبت بها كانت أحق، فلم تنتقل إلى من يدلي بها[١٤٥](٥).

٣. لأنه لا حق لأم الأم مع بقاء الأم، فلم تنتقل إليها، كالولي إذا عضل عن النكاح، فإن الولاية لا تنتقل إلى من دونه من الأولياء[١٤٦](٦).

---

(١٤١) انظر المغني (٤٢٧/١١).

(١٤٢) انظر حاشية ابن عابدين (٢٦٢/٥)، المهذب ٦٤٩/٠٤)، البيان (٢٨٢/١١).

(١٤٣) انظر الكافي لابن قدامة (٢٤٦/٣).

(١٤٤) انظر المغني (٤٢٧/١١).

(١٤٥) انظر المهذب (٦٤٩/٤).

(١٤٦) انظر البيان (٢٨٢/١١).

الترجيح:

الراجح . والله أعلم . هو قول الجمهور، وذلك لما يأتي:

أولا: لقوة أدلتهم.

ثانيا: لأنه لو ماتت الأم واجتمع الأب وأم الأم لقدمت أم الأم عليه بالاتفاق، فكذا هنا.

ثالثا: ما ذكره المخالفون من التعليل يجاب عنه بما يلي:

١. أما قولهم: بأن أم الأم فرع للأم فإذا سقط حق الأصل سقط حق الفرع، فيجاب عنه بأن كونهن فروع لها لا يوجب سقوط حقهن بسقوط حقها كما لو تزوجت الأم[١٤٧](١).

٢. أما قولهم بأن حق الأم لم يبطل بدليل إمكان مطالبتها فيجاب عنه بأنه لا مانع أن تطلب حقها والمحضون في حضانة أم الأم.

٣. أما قياسهم على الولي إذا عضل موليته والتعليل بعدم انتقال الولاية إلى من بعده، فيجاب بأن الولاية تنتقل إلى من بعده حتى يزوج المرأة.

(١٤٧) انظر المغني (١١/٤٢٧).

الفرع السادس: اجتماع الجد والأخت من الأب

اختلف العلماء – رحمهم الله تعالى – فيما إذا اجتمع الجد مع الأخت من الأب أيهما أحق بالحضانة على قولين:

القول الأول: أن الأخت من الأب أحق بالحضانة من الجد، وهذا مذهب الحنفية والمالكية[١٤٨](١) وهو وجه عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة[١٤٩](٢).

القول الأول: أن الجد أحق بالحضانة من الأخت من جهة الأب، وهذا مقتضى مذهب الشافعية والحنابلة[١٥٠](٣).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١. الأصل في ولاية الحضانة النساء، فإذا اختصم فيها جانب الرجال والنساء، قدم جانب النساء؛ لكونهن أعرف بالحضانة، وهنا الأخت تساويه في الدرجة لكنها تنفرد بمعرفة أحوال الحضانة،كتقديم الأم على الأب[١٥١](٤).

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١. لأن الجد يقوم مقام الأب عند فقد الأب، لذا يقدم على كل من يقدم عليه الأب[١٥٢](١).

---

(١٤٨) وأصلهم كما سبق أنهم يقدمون النساء على العصبة، فلا حضانة للعاصب مع النساء القريبات للمحضون. والفرق بين الحنفية والمالكية في الأب، وقد تقدم ذلك.

(١٤٩) انظر بدائع الصنائع (٤٥٧/٣)، الاختيار لتعليل المختار (٢٩٩/٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٢٧/٢)، المهذب (٦٤٧/٤)، البيان (٢٨٥)،

(١٥٠) انظر الحاوي الكبير (٥١٩/١١)، روضة الطالبين (١١٢/٩)، المغني (٤٢٦/١١)، كشاف القناع (٤٩٦/٥).

(١٥١) انظر المهذب (٦٤٧/٤)، البيان (٢٨٥/١١).

٢. لأن للجد إيلاد بعضية، وتعصيب فيقدم على الأخت كالأب[١٥٣][٢].

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول القاضي بتقديم الجد على الأخت من الأب، وذلك لما يأتي:

أولا: لقوة تعليل من قال بهذا القول، وموافقته للأصول حيث إن الأصل أن يكون الجد قائم مقام الأب عند فقده.

ثانيا: لأن الجد أصل والأخت فرع الجد، والأصل مقدم على الفرع.

ثالثا: لأن شفقة الجد على أحفاده أكمل من شفقة الأخت؛ لأنه يقوم مقام الأب.

رابعا: لأن الجد عاصب بنفسه، وأقوى من الأخت لأب في الإرث على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلذا يقدم عليها.

خامسا: لأنه يحصل تخيير الطفل بين الجد والأم عند ما تنتهي حضانة الأم، فدل ذلك على قوة الجد في الحضانة، ولذا يقدم على الأخت من الأب.

سادسا: أما قولهم بأن شفقة الأخت تفوق شفقة الجد على أحفاده، فيجاب بأنه غير مسلم؛ لأن شفقة الأصل لا تعادل إلا بشفقة الأصول، وإنما يقدم شفقة الأب والأم على شفقته لكون ولادتهما مباشرة للطفل.

---

(١٥٢) انظر الأم (٦/٢٤١).

(١٥٣) انظر المهذب (٤/٦٤٧)، البيان (١١/٢٨٥).

الفرع السابع: اجتماع المتساويين في الحضانة.

اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن للأقرب أحقية الانفراد بالحضانة إذا نازعه فيها غيره من المستحقين كالأخ الشقيق مثلا؛ فإنه ينفرد بالحضانة إذا نازعه فيها العم الشقيق، وهكذا يستحق الحضانة الأقرب فالأقرب؛ لأن الأقرب إليه يكون أشفق عليه، فيكون مقدما على غيره، رعاية لمصلحة الولد(١٥٤)[١].

واختلفوا في حالة تعدد من لهم الحق في الحضانة، واستووا في الدرجة من كل وجه، كما إذا كانا أخوين شقيقين أو عمين شقيقين أو ابني عم، ثم تنازعا في طلب الحضانة، ما هي طريقة حصول أحدهم على الانفراد بأحقية الحضانة؟

اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه ينظر إلى الأصلح منهما فيقدم الأصلح في أحقية الحضانة، فإن استويا في الصلاح، قدم الأسن، وهذا مذهب الحنفية والمالكية(١٥٥)[٢].

القول الثاني: أن أحقية الانفراد في الحضانة في مثل هذه الحالة تكون بالقرعة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة(١٥٦)[٣].

---

(١٥٤) انظر بدائع الصنائع (٤٦٠/٣)، الاختيار لتعليل المختار (٢٩٩/٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٢٧/٢)، الأم (٢٤٠/٦-٢٤١)، البيان (٢٨٠/١١)، كشاف القناع (٤٩٦/٥).

(١٥٥) انظر المبسوط (٢١٢/٥)، بدائع الصنائع (٤٦٠/٣)، الاختيار لتعليل المختار (٣٠٣/٣)، حاشية ابن عابدين (٢٦٥/٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٢٨/٢)، التاج والإكليل (٥٩٧/٥)، الفواكه الدواني (٦٧/٢)، حاشية العدوي (١٢١/٢).

(١٥٦) انظر المهذب (٦٤٨/٤)، فتح العزيز (١٠٩/١٠)، روضة الطالبين (١١٣/٩)، المغني (٤٢٧/١١)، الإنصاف (٤٨٨/٢٤).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١. لأن ضم الأصلح أنفع للولد؛ لأن يتخلق بأخلاقه الحسنة[١٥٧][١].

أما التقديم بالكبر عند استوائهم في الصلاح، فاستدلوا لذلك ما يلي:

١. بقصة القسامة، ففيها أن النبي ﷺ أمر أكبرهم أن يتكلم[١٥٨][٢]. فدل تقديم النبي ﷺ للكبير في الكلام . مع استواء الصغير مع الكبير في المطالبة بدم القتيل . على التقديم بالسن والتغليب بها[١٥٩][٣].

٢. لأن الأكبر أحرص على حفظه ومصلحته، وأكثر شفقة عليه في الأغلب، وكلها صفات تقوي استحقاقه الانفراد بالحضانة[١٦٠][٤].

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١. لأنه لا يمكن اجتماعهم على الحضانة، ولا مزية لأحدهما على الآخر في أصل الاستحقاق، فوجب التقديم بالقرعة[١٦١][٥].

٢. القياس على الزوجتين إذا أراد الزوج السفر بأحدهما، فإنه يقرع بينهما؛ إذا لا مرجح لأحدهما على الأخرى إلا بالقرعة، فكذلك المستوون في استحقاق الحضانة لا يقدم أحدهم إلا بالقرعة[١٦٢][٦].

---

(١٥٧) انظر المبسوط (٥/٢١٢).

(١٥٨) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/٢٥٢٨) في كتاب الديات باب القسامة رقم ٦٥٠٢

(١٥٩) انظر فتح الباري (١٢/٢٩٦).

(١٦٠) انظر أحكام الانفراد في الفقه الإسلامي (ص ٣٤٦).

(١٦١) انظر المهذب (٤/٦٤٨)، البيان (١١/٢٨٦)، الكافي لابن قدامة (٣/٢٤٦)، الشرح الكبير (٢٤/٤٨٨).

(١٦٢) انظر الكافي لابن قدامة (٣/٢٤٦).

الترجيح:

الراجح . والله أعلم . هو القول القاضي بتقديم الأصلح والأكثر شفقة، ثم الأسن؛ لتوقيره واحترامه، ثم إذا حصل التساوي في هذا الصفات كلها يلجأ بعد ذلك إلى القرعة، وذلك لما يلي:

أولا: لقوة أدلة من قال بهذا القول.

ثانيا: لأن ذلك موافق لمقاصد الشريعة؛ لأن الشرع حث على التعاون على البر والتقوى؛ بدليل قوله تعالى **قَالَ تَعَالَى:** ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢﴾ [١٦٣](١) وجعل المحضون تحت الأمين والأصلح من التعاون على البر والتقوى.

ثالثا: لأن الطفل في حالة التخيير عند من يقول بالتخيير، فاختار أحدهما مثلا الأب، وهو معروف بالدياثة وعدم صون الطفل من الفجور، والمعاصي بل يخاف أن يربيه على هذه المفاسد، والأم مأمونة تحفظه من هذا القاذورات، فإنه لا يمكن من الانضمام إلى أبيه حتى لا تفسد أخلاقه[١٦٤](٢)، فإذا كان هذا في الأبوين فمن عداهم من باب أولى.

رابعا: ما ذكروه من الأخذ بالقرعة مطلقا دون مراعاة للتفاوت في الصلاح والأمانة والشفقة قد تفوت الأحظ للمحضون؛ لأن القرعة قد تخرج لغير الأصلح فيفوز بأحقية الحضانة، ثم يربي الطفل على طريقة غير مرضية. فتلافيا من هذه العاقبة ينظر إلى الأصلح في الدين، والله أعلم.

---

(١٦٣) جزء آية من سورة المائدة رقم (٢).

(١٦٤) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٣١/٣٤).

خامسا: أما القياس على الزوجتين عند إرادة الزوج السفر بأحدهما، فيجاب عنه بأنه قياس مع الفارق، والفرق من وجوه:

١. لأن النص ورد في الأزواج ولم يرد النص في الحضانة.
٢. الزوجان ليسا مثل الطفل؛ لأنهما كبيران، والطفل صغير ما زال يتلقى التربية.
٣. لأن المكث في السفر تخالف المكث مع الطفل؛ فإن الزمن مع الطفل يطول، ويتلقى التربية من الحاضن، بخلاف الزوج بالنسبة لأزواجه.

المطلب الثالث: مدة الحضانة ونهايتها.

إتفق الفقهاء على أن الحضانة كحق الصغير تبدأ منذ ولادته؛ لقوله تعالى: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾﴾

وتكون في ظل الحياة الزوجية بين أمه وأبيه، يقومان بكفايته، الأب بالإتفاق عليه والأم بحضانته والحنو عليه. وأما في حال إنفصالهما بوفاة أو طلاق واستحقاق الحاضنة لها سواء كانت أما او غيرها، فإن مدة الحضانة تبدأ من أول الفرقة، واما نهايتها فهي محل الخلاف بين الفقهاء سواء كان المحضون ذكرا أو انثى، وبيان ذالك على النحو التالي:

حضانة الذكر:

تستمر حضانة الذكر حتى يستغني عن خدمة النساء، ويستقل بنفسه بالأكل والشرب والإستنجاء، وذالك ببلوغه سبع سنوات على المفتي به عند الحنفية[١٦٦] ودون تحديد لسن عند الزيدية[١٦٧] والإباطية [١٦٨] وإلى البللوغ عند المالكية[١٦٩] والظاهرية [١٧٠] وإلى سن التمييز في رواية عند المالكية[١٧١] وهو قول الشافعية[١٧٢] والحنابلة[١٧٣]

١٦٦-حاشية رد المحتار على الدرر المختار ج٣ ص٥٦٦.
١٦٧-التاج المذهب ج٢ ص٢٧٤.
١٦٨-شرح النيل وشفاء العليل ج٧ ص٤٠٨.
١٦٩-الكافي في فقه أهل المدينة ج١ ص٦٢٥.
١٧٠- المحلى ج١٠ ص١٤٣.

حضانة الأنثى:

تستمر حضانة الأنثى إلى المحيض عند الحنفية[١٧٤] والظاهرية[١٧٤] وإلى الزواج عند المالكية[١٧٥] وإلى بلوغها سبع سنوات عند الشافعية[١٧٦] والحنابلة[١٧٧] والزيدية[١٧٨]

وبالنظر إلى اختلاف الفقهاء في نهاية مدة حضانة الصغير، الذكر والأنثى،يتضح أن هذا الإختلاف نابع من النظر إلى مصلحة المحضون، والوصول به إلى بر والأمان، من حيث إستغنائه عن أمه، المنطوي على فرط الشفقة والحنان والعناية وتحمل المشاق في ملابسه القاذورات ونحوها،وإنتقاله إلى أبيه الأقدر على تكملة المسيرة في حفظه بالتربية والتعليم، وحفظ الأنثى من طمع الذي في قلبه مرض، وعليه فمن رأى أن الذكر يستغني باعتماده على نفسه في أمور حياته الطبيعية، التي كان تركه لدى الأم من أسبابها، قال بنهاية إلى تبين ذالك، ومن رأى أن استغناءه لن يتم إلا بالبلوغ، قال به، ومن رأى أن وصول الصغير إلى سن التمييز يجعله مستغنيا عن حضانة أمه، حيث نص العلماء أن سن التمييز به يستطيع الطفل التفريق بين النافع والضار قال بذالك.

١٧١-الكافي في فقه أهل المدينة ج١ ص٦٢٥

١٧٢-الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي ج٦ ص٢٤٠/دار السلام بالقاهرة/ الطبعة الأولى ١٤١

١٧٣-المغني ج٨ ص٢٣٩.

١٧٤-حاشية رد المحتار على الدرر المختار ج٣ ص٥٦٦. ونصو على أنه لو اختلفا في حيضها، فالقول قول الأم.

١٧٥-المحلى ج١٠ ص١٤٣.

١٧٦-الثقلين في الفقه المالكي ج١ ص١٣٨، الكافي في فقه أهل المدينة ج٢ ص٦٢٥.

١٧٧-الحاوي الكبير ج١١ ص٥٠١.

١٧٨_كشاف القناع للبهوتي ج٥ ص٥٠١، المغني ج٨ ص٢٤٠.

وأما الأنثى، فالأمر كذالك، إلا أنها لاختلاف طبيعتها الفسيولوجية، من نزول دم الحيض، وكونها يخاف عليها من طمع الطامعين، فضلا عن احتياجها إلى تعلم شؤون المنزل، رأى الفقهاء اختلاف استغنائها عن الذكر، وعليه فمن رأى أنها تستغني بالبلوغ، ومن بعده تحتاج إلى الصيانة والحفظ، والرجال على ذالك أقدر، قال بانتهاء الحضانة ببلوغها المحيض، ومن رأى أنها مع بلوغها المحيض ما زالت تحتاج إلى تعليم شؤونن المنزلية، وأن ذالك يستمر معها إلى أن تتزوج ، قال بضرورة إستمرارية حضانتها إلى ذلك، ومن رأى أن الأنثى بعد بلوغها سن التمييز ، تحتاج إلى الحفظ والصيانة ، وأن الأمر لا يتوقف على البلوغ، حيث نظروا إلى أن الأم تحتاج إلى من يحفظها، فهي أضعف من أن تحفظ غيرها، قال بانتهاء حضانتها بمجرد بلوغها هذا السن.

ويتبين أيضا أنه لا ولاية لغير الأم من الحواضن بعد استقلال المحضون مع وجود الاب[١٧٩] [١] وجدير بالذكر أنه لم يرد في الشريعة نص في تحديد سن استغناء المحضون عن حاضنته، ولم يرد أيضا تحديد بلوغ حد الشهوة عند المحضونة؛ لان جميع ذلك يختلف باختلاف البينة الجسدية، والبينة المحيطة. وعليه فلا يمكن الترجيح بين المذاهب الفقهية في هذا. والله تعالى أعلم [٢]

١٧٩-التاج المذهب ج٢ ص٢٧٥.

الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات الطيبات وتزداد يشكر، العطايا والبركات، وبعد فقد توصلت من خلال البحث إلى النتائج الآتية:

أولا النتائج:

- أن الحضانة تعني قيام الحاضن بشؤون المحضون قياما تاما إلى الوقت الذي يستطيع فيه أن يكون قادرا على رعاية نفسه وأن يستقل عن غيره.
- الحضانة مشروعة من الكتاب والسنة والإجماع,
- حكم الحضانة التكليفي هو الوجوب على الكفاية، إذا قام به من يصلح لها، سقط الإثم عن الباقين،
- تتمثل شروط إستحقاق الحضانة في شروط مشتركة بين الرجال والنساء، وأخرى تختص بها النساء وأخرى يختص به الرجال.
- يشترك النساء والرجال في ثمانية شروط مجتمعة، لاستحقاق الحضانة، تتمثل في: الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والرشد، والحرية، وعدم القسوة ، وصحة الجسم، والأمانة، وأمن المكان، وإقامة وطن واحد.

- تختص النساء بثلاثة شروط هي: أن تكون ذات رحم محرم من المحضون كأمه وأخته، وأن تكون محرمة عليه، وأن تكون خالية عن الزوج الأجنبي من المحضون ، وان تكون مرضعة للمحضون إن كان رضيعا عند الشافعية.
- يشترط للحاضن ليكون مستحقا للحضانة: أن يكون محرما للمحضون إن كان المحضون أنثى مشتهاة، وأن عنده من يحضن الطفل من النساء.
- في ترتيب المستحقين للحضانة خلاف بين الفقهاء مع اتفاقهم على ان احق النساء بحضانة الصغير هي أمه،
- تبدأ مدة الحضانة من ولادة الصغير وتستمر في فترة الزوجية، وإلى بلوغ الصغير والصغيرة إلى الخامسة عشرة.
- على الوالدين عدم مضارة بعضهما، فيما يخص رؤية المحضون، وعليهما اتباع النظر الصحيح في مصلحة المحضون والحفظ عليه.

ثانيا: التوصيات.

أوصي- والله تعالى أسأل أن أكون أهلا للإيصاء – توصي الباحثة نفسها ثم المجتمع بتقوالله عز وجل، واتباع شريعة الله وأوامره واجتناب ما نهى عنه، واعطاء الأولاد حقوقهم ليست بتنمية جسمهم فقط بل بتنشئتهم وتربيتهم بأخذ شريعة الله والأخلاق الحسنة.

الفهارس:

فهرس الأيات:

رقم	شطرالأية	السور	رقم الأية	الصفة
١.	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾	الإسراء:	٢٤	٢٢
٢.	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ	ّالبقرة	٢٣٣	٢٣
٣.	قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿۞وَحَرَّمۡنَا عَلَيۡهِ ٱلۡمَرَاضِعَ مِن قَبۡلُ فَقَالَتۡ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰٓ أَهۡلِ بَيۡتٖ يَكۡفُلُونَهُۥ لَكُمۡ وَهُمۡ لَهُۥ نَٰصِحُونَ ١٢﴾	القصص	٢	٢٣
	﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢﴾	المائدة:		٧٣

فهرس الأحاديث:

رقم	طرق الحديث	راوى الأعلى	الصفحة
١.	**فخرج النبي–صلى الله عليه وسلم– فذكر حديثا قال: (وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم)**	علي بن أبي طالب	**٢٣**
٢.	فقال لها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (أنت أحق به ما لم تنكحي.	عمرو بن شعيب	**٢٤**
٣.	قال النبي صلي الله عليه وسلم)كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه،		**٢٩**
٤.	.لأن النبي صلى الله عليه وسلم– خير علاما بين أمه وأبيه		**٦٠**
٥.	أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أكبرهم أن يتكلم.		**٧٢**

المصادر والمراجع:

١-رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج٣ ص٥٥٥/ دار الفكر، بيروت الطبعة الثانية.
٢-بدائع الصنائع للكاساني ج٤ ص٤٠/ دار الكتب العلمية ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م.
٣-شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، تأليف: الشيخ محمد عليش ج٤ ص٤٢٠/ طباعة ونشر دار الفكر، بيروت – لبنان ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م.
٤-الحاوي الكبير للماوردي ج١٥ ص١٠٠/ دار الكتب العلمية ١٤١٤هـ- ١٩٩٩م
٥- مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني ج٥ ص٦٦٥/ المكتب الإسلامي- الطبعة الثانية ١٤١٥هـ-١٩٩٤م.
٦-نهاية المحتاج للرميلي ج٧ ص٢٢٥/ دار الفكر بيروت.
٧- البدائع: ج٤ ص ٤٠، الشرح الصغير: ج٢ ص٧٥٦، مغني المحتاج: ج٣ ص٤٥٢، كشاف القناع: ج٥ ص٥٧٦.
٨- مختار الصحاح ج١ ص٤٣٥) وقال الجرجاني: هي تنفيذ القول على الغير شاء الغير أم أبى.(التعريفات للجرجاني ج١ ص٢٤٥.
٩- المهذب للشيرازي ج٣ ص١٦٤/ دار الكتب العلمية، الكافي في فقه الإمام أحمد ج٣ ص٢٤٤/ دار الكتب العلمية، مطالب أولى النهى ج٥ ص٦٦٥/ المكتب الإسلامي، الروضة الندية للقنوجي ج٢ ص٩١/دار إبن عفان.
١٠-الفتاوى الهندية لأبي المظفر ج١ ص٥٤١، حاشية در المحتار على الدر المختار ج٣ ص٥٥٩،
١١-المقدمات الممهدات ح٢ ص٤٣٧، حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة بن أبي زيد وهي حاشية العلامة الشيخ على الصعيدي العدوي ح٢ ص١٢٩، ١٣٠/ طبعة دار إحياء الكتب العربية- عيسى ألبابي الحلبي وشركاه، حاشيتا قليوبي وعميرة ح٤ ص٩٢/ مطبعة مصطفى ألبابي الحلبي/ الطبعة الثالثة ١٣٧٥هـ-١٩٥٦م.

١٢-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١٠ ص٢٤٤/دار الكتب المصرية بالقاهرة.
١٣-جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي بن جرير الطبري ج١٧ ص٤٢٠/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة الأولى. ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م.
١٤-جامع البيان في تأويل القرآن ج١٨ص٣٠٥.
١٥- أخرجه أبو داود في سننه/ كتاب الطلاق/باب من أحق بالولد ج٦ ص٣٧٤ رقم ٢٢٧٩، وسكت عنه فهو أحسن.
١٦- عون المعبود لأبي الطيب آبادي ج٦ ص٣٧١/ دار الكتب العلمية ، بيروت.
١٧- أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق/ باب من أحق بالولد ج٦ ص٣٧١ رقم ٢٢٧٧.
١٨- سبل السلام للصنعاني ج٣ ص١٥٦٠/ دار الفكر ١٩٩٥م.
١٩- المقدمات الممهدات ج١ ص٥٦٤/دار الغرب الإسلامي/ الطبعة الأولى ١
٢٠- البيان في مذهب إمام الشافعي ج١١ ص٢٧٥، الإقناع الخطيب الشربيني ج٢ ص٤٩١/ دار الفكر بيروت.
٢١-الكافي في فقه الإمام أحمد ج٣ ص٢٤٥.
٢٢-شرح فتح القدير للكمال بن المهام ج٨ ص٣١٠ / دار الكتب العلمية.
٢٣-شرح مختصر الخليل للخرشي ج٤ ص٢١٢/ دار الفكر.
٢٤- المحلى لابن حزم ج١٠ ص١٤٣/ دار الفكر بيروت.
٢٥- . النهاية في غريب الحديث والأثر لابن أثير ج١ ص٢٤٧ / المكتبة العلمية بيروت، ٥١٣٩٩-١٩٧٩م.
٢٦- أخرجه البخاري في صحيحه، واللفظ له/ كتاب الجنائز/ باب ما قيل في أولاد المشركين ج١ص٤٦٤ رقم ١٣٦١، مسلم في صحيحه/ كتاب القدر/ باب كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ج١٦ ص ١٧٧ رقم ٦٠٧٦.
٢٧- عمدة القاري للعيني ج٨ ١٦٨/ دار الفكر.
٢٨- الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين ج١٣ ص٥٣٨ بتصرف/ دار ابن الجوزي/ الطبعة

الأولى ١٤٢٢-١٤٢٨هـ.

٢٩- تبيين القائق للزيلعي ج٣ ص٤٩/ المطبعة الكبرى الأميرية، العناية على الهداية للبابرتي ج٤ ص٣٦٩.

٣٠- البحر الائق لابن نجيم ج٤ ص١٧٩/ دار الكتاب الإسلامي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج٣ ص٧٥٨، الإقناع للشربيني الخطيب ج٢ ص٤٩١/ دار الفكر، البحر الزخار لابن المرتضى ج٤ ص٢٨٤/دار الكتاب الإسلامي، شرح النيل ج٧ ص٤٠٧الل

٣١- شرح مختصر خليل ج٤ ص٢١٢.

٣٢- المبسوط للسرخسي ج٥ ص٢١٣/ دار المعرفة.

٣٣- مغني المحتاج للشربيني الخطيب ج٥ ص١٩٥/ دار الكتب العلمية .

٣٤- مطالب أولي النهى ج٥ ص٦٦٧، الكافي في فقه الإمام أحمد ج٣ ص٢٤٥.

٣٥- مغني المحتاج ج٥ ص١٩٥، وجاء في شرح مختصر خليل ج٤ ص٢٠٨: قال مالك: وإذا أعتق ولد الأمة وزوجها حر فطلقها فهي أحق بحضانة ولدها.

٣٦- المحلى ج١٠ ص١٤٣.

٣٧- شرح مختصر خليل ج٤ ص ٢١١، الفواكه الدواني ج٣ ص٦٧.

٣٨-البحر الرائق ج٤ ص١٧٩، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج٢ ص٧٥٨. شرح النيل ج٧ ص٤٠٧.

٣٩- التاج والإكليل ج٥ ص٥٩٧، الفواكه الدواني ج٢ ص٦٧. التاج المذهب ج٢ ص١٨٧/ مكتبة اليمن.

٤٠- الفواكه الدواني ج٢ ص٦٧، أسنى المطالب ج٣ ص٤٤٨، نيل المآرب بشرح دليل الطالب لعبد القادر التغلبي ج٢ ص٣١١/ مكتبة الفلاح بالكويت/ الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م، كشاف القناع ج٥ ص٥٠٣.التاج المذهب ج٢ ص٢٦٩.

٤١- شرح مختصر الخليل ج٤ ص٢١١، الفواكه الدواتي ج٢ ص٦٧، شرح النيل ج٧ص ٤٠٧.
٤٢- شرح مختصر خليل ج٤ ص٢١٥، حاشية السوقي على الشرح الكبير ج٢ ص٥٣١.
٤٣- حاشيتا قليوبي وعميرة ج٤ ص٩٣. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية للأنصاري ج٣ ص٤٠٩.
٤٤- كشاف القناع للبهوتي ج٥ ص٥٠٠/ دار الكتب العلمية، الفتاوى الكبرى الابن تيمية ج٣ ص٦٤١/دار الكتب العلمية.
٤٥- المحكم والمحيط الاعظم لابن سيدة ج٩ ص٣٢٣/ دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.
٤٦- بدائع الصنائع ج٤ ص٤٤ بتصرف، وأنظر أيضا الفتاوى الهندية ج١ ص٥٤٣
٤٧- زاد الميعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية ج٥ ص٤١٤/ مؤسسة الرسالة بيروت، مكتبة المنار الإسلامية بالكويت/ الطبعة ١٤١٥/٢٧هـ-١٩٩٤م.
٤٨- المقدمات الممهدات ج١ ص٥٦٤، حاشية العدوي علي كفاية الطالب الرباني ج٢ ص١٣١/ دار الفكر، بيروت ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.
٤٩- المحيط البرهاني لابن مازة ج٣ ص١٧٨/ دار الكتب العلمية، الكافي في فقه الإمام أحمد ج٣ صجح٢٤٦.العناية ج٣ ص٣٧٠. شرح ميارة ج١ ص٢٧٣/ دار المعرفة، نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ج١٥ص٥٤٩/ دار المنهاج، العدة ج١ ص٤٧٨، شرح النيل ج٧ص٤١٠.
٥٠- موسوعة الفقه الإسلامي والقضيا المعاصرة للوهبة الزحيلي ج٨ ص ٦٧٩.
٥١-البدائع: ٤/ ٤١-٤٤، الدرر المختار: ٢/ ٨٧١ وما بعدها ٨٧٧ وما بعدها، فتح القدير: ٣/٣١٣-٣١٧، الكتاب مع اللباب: ٣/١٠١-١٠٣، القوانين الفقهية: ص٢٢٤، الشرح الصغير: ٢/٧٥٦ وما بعدها، المهذب:٢/ ١٦٩-١٧١، مغني المحتاج: ٣/ ٤٥٢-٤٥٤، كشاف القناع: ٥/٥٧٦ وما بعدها، غاية المنتهى: ٣/٢٤٩، المغني: ٧/٦١٣، ٦١٩-٦٢٤.
٥١- رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه إسناده.
٥٢- رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي ايوب وهو صحيح.

٥٣- المو سوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة ج٨ ص- ٦٨٢

٥٤-المحيط البرهاني ج٣ ص١٧٨.

٥٥-المقدمات الممهدات ج١ ص

٥٦- شرح مختصر خليل للخرشي ج٤ ص٢١٠،٢٠٩،

٥٧-المهذب ج٣/ ١٦٦.

٥٨المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد للحرائي ج٢/ص١١٩.

٥٩-المو سوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة ج٨ ص٦٩٠-٦٩١.

٦٠- القوانين الفقهية: ص٢٢٤ ، الشرح الصغير: ٢/ ٧٥٩ وما بعدها ، المقدمات الممهدات:

٥٦٩/١ وما بعدها، الدرر المختار ورد المحتار: ٢/ ٨٨٠. وما بعدها، المغني: ٦١/٧

٦٠- الدرر المختار ٢/ ٨٨٠، الشرح الصغير: ٧٦٣/٢، وما بعدها، مغني المحتاج: ٤٥٦/٣. كشاف القناع: ٥٨٠/٥

٦١- أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣١٠/١١) رقم ٦٧٠٧، وأبو داود في سننه (٦٩٣/١) في كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، رقم ٢٢٧٦، وعبد الرزاق في المصنف (١٥٣/٧) في كتاب الطلاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، رقم ١٢٥٩٦، والحاكم في المستدر (٢٢٥/٢) في كتاب الطلاق، والدراقطني في سننه (٣٠٤/٣) رقم ٢١٨، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/٨) في كتاب النفقات، باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد، كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحديث صححه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. والشيخ الألباني حسن ا لحديث؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر الإرواء (٢٤٤/٧) برقم ٢١٨٧.

٦٢- المغني (٤١٣/١١-٤١٤).

٦٣- أسنى المطالب (٤٥٣/٣)، مغني المحتاج (٥٩٤/٣)، الإنصاف (٤٥٨/٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٢٤٩/٣).

٦٤-بدائع الصنائع (٣/٤٥٦، ٤٦٩-٤٧٠).
٦٥-كشاف القناع (٥/٤٩٦)، فقه الدليل (٥/٣٨٩).
٦٦-مغني المحتاج (٣/٥٩٤).
٦٧-سبق تخريجه في ص (٦٦٣).

٦٨- فتح العزيز (١٠/١٠٤).
٦٩- المهذب (٤/٦٤٥)، البيان (١١/٢٨٠-٢٨١)، روضة الطالبين (٩/١١٠).
٧٠- المهذب (٤/٦٤٥)، البيان (١١/٢٨٠-٢٨١)، المغني (١١/٤٢٤).
٧١- المصدرين السابقين.
٧٢- المغني (١١/٤٢٥)
٧٣- بدائع الصنائع (٣/٤٦٠)، البيان (١١/٢٨١)، المغني (١١/٤٢٤).
٨٤- حاشية الدسوقي (٢/٥٢٧-٥٢٨)، بلغة السالك (٢/٧٥٦-٧٥٧).
٧٥- الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/٥٢٧)، بلغة السالك (٢/٧٥٦)، شرح الخرشي (٤/٢٠٩)، الفواكه الدواني (٢/١٠٣)، المحلى (١٠/٣٢٣).
٧٦-مختصر المزني مع الحاوي الكبير (١١/٥١٧)، المهذب (٤/٦٤٦)، مغني المحتاج (٣/٥٩٤)، المغني (١١/٤٢٦)، الإنصاف (٢٤/٤٥٨).
٧٦- بدائع الصنائع (٣/٤٥٦)، شرح الخرشي (٤/٢٠٨).
٧٧- مغني المحتاج (٣/٥٩٤)، المغني (١١/٤٢٦)، الشرح الكبير (٢٤/٤٥٨).
٧٨- مختصر المزني مع الحاوي الكبير (١١/٥١٧)، المهذب (٤/٦٤٦)، فتح العزيز (١٠/١٠٧)، المغني (١١/٤٢٦).
٧٩- الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/٥٢٧)، شرح الخرشي (٤/٢٠٩)، المهذب (٤/٦٤٦)، البيان (١١/٢٨٣)، روضة الطالبين (٩/١١٢)، المغني (١١/٤٢٦)، الإنصاف (٢٤/٤٥٩).
٨٠-الحاوي الكبير (١١/٥١٩)، المهذب (٤/٦٤٦) فتح العزيز (١٠/١٠٧).

٨١- الحاوي الكبير (٥١٩/١١).
٨٢-شرح الخرشي (٢٠٨/٤)، البيان (٢٨٣/١١)، فتح العزيز (١٠٧/١٠).
٨٣- المهذب (٣٤٦/٤)، البيان (٢٨٣/١١).
٨٤- المبسوط (٢١٢/٥)، بدائع الصنائع (٤٥٩/٣)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١٠٩/٢).
٨٥- بدائع الصنائع (٤٥٩/٣)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١٠٨/٢-١٠٩)، الفتاوى الهندية (٢٦٧/١)، حاشية ابن عابدين (٢٧٠/٥).
٨٦- الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٢٦/٢)، مواهب الجليل (٢١٤/٤).
٨٧- المدونة (٢٥٨/٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٢٦/٢)، مواهب الجليل من أدلة الخليل للشنقيطي (٢٤٥/٣).
٨٨-المهذب (٦٤٩/٤)، الشرح الكبير (٤٨٨/٢٤).
٨٩- مختصر المزني مع الحاوي الكبير (٥٢٢/١١)، المهذب (٦٥١/٤)، البيان (٢٩٠/١١)، فتح العزيز (٩٦/١٠)، روضة الطالبين (١٠٤/٩).
٩٠- الإرشاد (ص ٣٢٧)، المغني (٤١٧/١١، ٤١٨)، الإنصاف (٤٨٣/٢٤، ٤٩٠)، كشاف القناع (٥٠١/٥-٥٠٣)، فقه الدليل (٣٩٤/٥، ٣٩٦).
٩١- بدائع الصنائع (٤٦١/٣).
٩٢- المغني (٤١٥/١١).
٩٣- مواهب الجليل من أدلة الخليل (٢٤٥/٣).
٩٤- سبق تخريجه في ص (٦٦٣)
٩٥- زاد المعاد (٤٢٥/٥).
٩٦-أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف (١٨٠/٤) في كتاب الطلاق، باب ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد، رقم ١٩١٢٧، وعبد الرزاق في المصنف (١٥٦/٧) في كتاب الطلاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، رقم ١٢٦٠٩، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/٨) في كتاب النفقات، باب الأم أحق بولدها ما لم تتزوج كلهم من طريق عمار الجرمي. والحديث ضعفه الشيخ الألباني

في الإرواء (٧/٢٥٠-٢٥١) رقم ٢١٩٥)

٩٧- مغني المحتاج (٣/٥٩٨)، تحفة المحتاج (٨/٢٦٠)، نهاية المحتاج (٧/٢٣١).

٩٨- المغني (١١/٤١٨)، كشاف القناع (٥/٥٠٢).

٩٩- المغني (١١/٤١٦)، الشرح الكبير (٢٤/٤٨٥).

١٠٠-المعني (١١/٤١٧)، الشرح الكبير (٢٤/٤٨٩).

١٠١- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٤/١٢٣-١٢٨).

١٠٢- مواهب الجليل من أدلة الخليل (٣/٢٤٥).

١٠٣-فتح العزيز (١٠/٩٥)، المجموع المذهب في قواعد المذهب (٢/٤٦٠-٤٦٢)، مغني المحتاج (٣/٥٩٨)، المغني (١١/٤١٧)، مطالب أولى النهى (٥/٦٦٧).

١٠٤- بدائع الصنائع (٣/٤٥٧)، حاشية ابن عابدين (٥/٢٦٣)، التاج والإكليل (٥/٥٩٦)، شرح الخرشي (٤/٢٠٧)، مختصر المزني مع الحاوي (١١/٥١١)، المهذب (٤/٦٤٤)، فتح العزيز (١٠/١٠٢)، المغني (١١/٤٢٣)، الإنصاف (٢٤/٤٦٠)، كشاف القناع (٥/٤٩٧).

١٠٥-مختصر المزني مع الحاوي الكبير (١١/٥١١)، المهذب (٤/٦٤٤)، روضة الطالبين (٩/١٠٩)، المغني (١١/٤٢٣)، الإنصاف (٢٤/٤٦١).

١٠٦-بدائع الصنائع (٣/٤٥٧)، حاشية ابن عابدين (٥/٢٦٣)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/١٠٧)، شرح الخرشي (٤/٢٠٩)، منح الجليل (٤/٤٢٢)، الحاوي الكبير (١١/٥١٤)، الإنصاف (٢٤/٤٦١)، كشاف القناع (٥/٤٩٧).

١٠٧- الحاوي الكبير (١١/٥١٤)، المغني (١١/٤٢٣)، الشرح الكبير (٢٤/٤٥٩).

١٠٨- الحاوي الكبير (١١/٥١٤)، المغني (١١/٤٢٣).

المغني (١١/٤٢٣).

١٠٩-بدائع الصنائع (٣/٤٥٧)، حاشية ابن عابدين (٥/٢٦٣)، الحاوي الكبير (١١/٥١٤)، المهذب (٤/٦٤٤)، فتح العزيز (١٠/١٠٢)، المغني (١١/٤٢٣)، كشاف القناع (٥/٤٩٧).

١١٠-مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٢٣/٣٤ وما بعدها، زاد المعاد (٣٩٣/٥).

١١١-الحاوي الكبير (٥١٤/١١)، المغني (٤٢٣/١١).

١١٢-حاشية ابن عابدين (٢٦٣/٥)، روضة الطالبين (١٠١/٩)، المغني (٤٢٧/١١)، الإنصاف (٤٦٦/٢٤)، كشاف القناع (٤٩٨/٥).

١١٣-روضة الطالبين (١٠١/٩)، المغني (٤٢٧/١١)، الإنصاف (٤٦٦/٢٤).

١١٤-روضة الطالبين (١٠١/٩).

١١٥-المغني (٤٢٧/١١).

١١٦- حاشية ابن عابدين (٢٦٢/٥)، المهذب ٦٤٩/٠٤)، البيان (٢٨٢/١١).

١١٧- الكافي لابن قدامة (٢٤٦/٣).

١١٨- المغني (٤٢٧/١١).

١١٩- المهذب (٦٤٩/٤).

١٢٠-البيان (٢٨٢/١١).

١٢١-المغني (٤٢٧/١١).

١٢٢-المغني (٤٢٧/١١).

١٢٣- بدائع الصنائع (٤٥٧/٣)، الاختيار لتعليل المختار (٢٩٩/٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٢٧/٢)، المهذب (٦٤٧/٤)، البيان (٢٨٥)،

١٢٤-الحاوي الكبير (٥١٩/١١)، روضة الطالبين (١١٢/٩)، المغني (٤٢٦/١١)، كشاف القناع (٤٩٦/٥).

١٢٥-المهذب (٦٤٧/٤)، البيان (٢٨٥/١١).

١٢٦- الأم (٢٤١/٦).

١٢٧- المهذب (٦٤٧/٤)، البيان (٢٨٥/١١).

١٢٨- بدائع الصنائع (٤٦٠/٣)، الاختيار لتعليل المختار (٢٩٩/٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٢٧/٢)، الأم (٢٤٠/٦-٢٤١)، البيان (٢٨٠/١١)، كشاف القناع (٤٩٦/٥).

١٢٩-المبسوط (٢١٢/٥)، بدائع الصنائع (٤٦٠/٣)، الاختيار لتعليل المختار (٣٠٣/٣)، حاشية ابن عابدين (٢٦٥/٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٢٨/٢)، التاج والإكليل (٥٩٧/٥)، الفواكه الدواني (٦٧/٢)، حاشية العدوي (١٢١/٢).

١٢٩- المهذب (٦٤٨/٤)، فتح العزيز (١٠٩/١٠)، روضة الطالبين (١١٣/٩)، المغني (٤٢٧/١١)، الإنصاف (٤٨٨/٢٤).

١٣٠- المبسوط (٢١٢/٥).

١٣١- أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٢٨/٦) في كتاب الديات باب القسامة رقم ٦٥٠٢

١٣٢-فتح الباري (٢٩٦/١٢).

١٣٣- أحكام الانفراد في الفقه الإسلامي (ص ٣٤٦).

١٣٤- المهذب (٦٤٨/٤)، البيان (٢٨٦/١١)، الكافي لابن قدامة (٢٤٦/٣)، الشرح الكبير (٤٨٨/٢٤).

١٣٥- الكافي لابن قدامة (٢٤٦/٣).

١٣٦- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٣١/٣٤).

١٣٧-حاشية رد المحتار على الدرر المختار ج٣ ص٥٦٦.

١٣٨-التاج المذهب ج٢ ص٢٧٤.

١٣٩-شرح النيل وشفاء العليل ج٧ ص٤٠٨.

١٣٠-الكافي في فقه أهل المدينة ج١ ص٦٢٥.

١٤١- المحلى ج١٠ ص١٤٣.

١٤٢-الكافي في فقه أهل المدينة ج١ ص٦٢٥

١٤٣-الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي ج٦ ص٢٤٠/دار السلام بالقاهرة/ الطبعة الأولى ١٤١

١٤٤-المغني ج٨ ص٢٣٩.

١٤٥-حاشية رد المحتار على الدرر المختار ج٣ ص٥٦٦. ونصو على أنه لو اختلفا في حيضها، فالقول قول الأم.

١٤٦-المحلى ج١٠ ص١٤٣.

الثقلين في الفقه المالكي ج١ ص١٣٨، الكافي في فقه أهل المدينة ج٢ ص٦٢٥.

١٤٧-الحاوي الكبير ج١١ ص٥٠١.

١٤٩-كشاف القناع للبهوتي ج٥ ص٥٠١، المغني ج٨ ص٢٤٠

١٥-التاج المذهب ج٢ ص٢٧٥.

فهرس الموضوعات:

البسملة ..... ب
الإستهلال : ..... ج
إهداء : ..... هـ
كلمة الشكر والتقدير: ..... و
المقدمة ٥
أسباب إختيار هذا الموضوع: ٦
أهمية الموضوع: ٧
أهداف البحث: ٨
أسئلة البحث: ٨
فرضيات البحث: ٩
حدود البحث: ١١
أدوات البحث: ١١
منهج البحث: ١٢
هيكل البحث: ١٣
الفصل الثاني:تعريف الحضانة في الفقه الإسلامي ١٤

المبحث الأول: تعريف الحضانة، ١٤
الفصل الأول :مفهوم الحضانة، حكم الحضانة ،مشروع الحضانة ١٦
المبحث الأول تعريف الحضانة، حكم الحضانة ،مشروعية الحضانة حكمة مشروعية الحضانة. وفيه
أربعة مطالب: ١٧
المطلب الأول: تعريف الحضانة لغة واصطلاحا. ١٧
المطلب الثاني: حكم الحضانة. ٢٠
المطلب الثالث:مشروعية الحضانة. ٢١
المبحث الثاني: شروط إستحقاق الحضانة. ٢٧
المطلب الثالث: عودة الحق في الحضانة. ٤٦
المطلب الثاني: ثبوت الحضانة للعصبة، وفيه ثلاثة فروع: ٤٧
المطلب الثالث: اجتماع العصبة مع غيرهم، وفيه سبعة فروع: ٥٨
المطلب الثالث: مدة الحضانة ونهايتها. ٧٩
الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. ٨٢
الفهارس: ٨٥
فهرس الأحاديث: ٨٦
فهرس الموضوعات: ٩٨